TRATADO DE DERECHO DISCIPLINARIO

PARTE SUSTANCIAL GENERAL

CARLOS ARTURO
GÓMEZ PAVAJEAU
JOHN HARVEY
PINZÓN NAVARRETE

TRATADO DE DERECHO DISCIPLINARIO

TOMO I

PARTE SUSTANCIAL GENERAL

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Gómez Pavajeau, Carlos Arturo

Tratado de derecho disciplinario. Tomo I, Parte sustancial general / Carlos Arturo Gómez Pavajeau, John Harvey Pinzón Navarrete. -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2021.
801 páginas ; 24 cm.

Incluye referencias bibliográficas (páginas 759-801)

ISBN: 9789587905779

1. Derecho disciplinario – Colombia 2. Sanciones disciplinarias – Colombia 3. Proceso disciplinario – Colombia 4. Derecho administrativo -- Colombia I. Pinzón Navarrete, John Harvey II. Universidad Externado de Colombia III. Título

344 SCDD 15

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP

abril de 2021

ISBN 978-958-790-577-9

© 2021, CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU
© 2021, JOHN HARVEY PINZÓN NAVARRETE
© 2021, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá
Teléfono (57 1) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co

Primera edición: abril de 2021

Corrección de estilo: Óscar Torres Angarita
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Composición: Marco Robayo
Impresión y encuadernación: Panamericana, Formas e Impresos S.A.
Tiraje: de 1 a 1.000 ejemplares

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

AGRADECIMIENTOS POR PARTE DE CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU

Mis agradecimientos a mi Universidad Externado de Colombia. En ella me formé como estudiante, crecí y sigo haciéndolo como investigador, docente y académico.

Allí he forjado grandes amigos, casi hermanos. También un sinnúmero de alumnos que siguen mi pensamiento, no como escuela sino como tendencia, y con base en ese seguimiento reflexivo, y para nada genuflexo, han participado conmigo en obras colectivas y como coautores; sería muy difícil aquí enunciarlos, se volvería demasiado extenso este símbolo de agradecimiento.

Particularmente profeso gran admiración y respeto por John Harvey Pinzón Navarrete, David Alfonso Roa Salguero y Mauricio Rodríguez Tamayo. Sus obras son, marginando de ellas mi pensamiento, aportes significativos al Derecho Disciplinario en Colombia. Una nueva etapa transito con ellos, hombro a hombro y codo a codo, nuevos trabajos en coautoría y otros inicialmente elaborados por mí, pero ahora con el aporte significativo e invaluable colaboración de ellos en su actualización y reelaboración.

Es lo que sucede en particular con esta obra, puesto que, sobre la base de publicaciones realizadas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura en el año de 2015, se lleva a cabo una integración sistemática con todos mis escritos generales y particulares llevados a cabo hasta el día de hoy. No se trata de una compilación ni de agregados mecánicos de escritos, sino de una verdadera sistematización de mi pensamiento por medio de una reelaboración de mis conceptos explícitos e implícitos sobre la materia, complementados con el inteligente toque personal-tendencial de mi querido y apreciado discípulo Pinzón Navarrete, sin duda alguna un adalid avanzado, con nombre e identidad propia, hoy en el Derecho Disciplinario.

Se expone mi pensamiento pero a la par, en un gesto de gallardía ante mí, cuando no se está de acuerdo con mi conceptualización en temas particulares, expone sus particulares criterios como muestra de honestidad y dignidad académica.

Un tratado pretende abarcar toda la materia mediante su exposición orgánica y sistemática. Así lo ha logrado Pinzón Navarrete al actualizar con una visión transversal de la materia, desde las diferentes ópticas en que se

manifiesta, para exponer una visión global y sobre todo constitucional de un Derecho Disciplinario Único, autónomo e independiente *made in Colombia*.

Esta fue mi inspiración y aspiración a medida que crecían mis escritos en calidad y cantidad, a veces dispersos por virtud de los temas tratados y su importancia temporal nacional e internacional, por obra de las discusiones suscitadas en el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario y en la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario, en cuyas instituciones nos han acompañado con su sabio consejo y directriz Jaime Bernal Cuéllar, Rafael de Ostau Lafont-Pianetta y Edgardo José Maya Villazón, quien puede considerarse la persona que lanzó las palabras mágicas que han hecho posible estas ideas, cuando como orientación para el ejercicio de mi cargo como magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en 1992, me instruyó en la idea de trabajar sobre un "*Derecho disciplinario autónomo e independiente*", ideas sobre las cuales Carlos Gustavo Arrieta Padilla, también nuestro gran consejero académico del ICDD, como Procurador General de la Nación impulsó la creación de la Ley 200 de 1995, continuado por los doctores Bernal Cuéllar y Maya Villazón con la Ley 734 de 2002.

Esta obra es el tomo I del pretendido *Tratado de Derecho Disciplinario*, cuyos siguientes volúmenes paulatinamente se irán completando con la coautoría de mis más apreciados discípulos, no en un ejercicio académico de "*escuela*" sino de "*una tendencia*".

Para su construcción normativa se partió fundamentalmente de la Ley 270 de 1996, la Ley 734 de 2002, la Ley 1123 de 2007, actualizada con la Ley 1952 de 2019.

No podría ser de otra manera:

Dedico este trabajo a las enseñanzas en libertad y en el respeto por la libertad de conciencia, creencia y pensamiento que profesa la Universidad Externado de Colombia, generadora, garante y custodia de las mismas, propiciando y permitiendo una academia y docencia libres y críticas, lo que las hace creativas y productivas, ejemplo de gallardía y rechazo a la a veces doctrina genuflexa y ejemplo de capitis diminutio que solamente ve en lo extranjero lo digno de seguir y admirar. Siempre con la frente en alto.

AGRADECIMIENTOS POR PARTE DE JOHN HARVEY PINZÓN NAVARRETE

La presentación de un texto a la comunidad académica es una magnífica oportunidad para manifestar públicamente el agradecimiento a varias personas por razones de todo orden.

En primer lugar, al maestro Carlos Arturo Gómez Pavajeau, no solo por la invitación a que uniéramos esfuerzos para lograr la culminación de este trabajo, sino por su constante liderazgo, alegre motivación y continua enseñanza. No exagero al afirmar que desde el año 2008 a la fecha no ha pasado un solo día en que no haya aprendido algo de mi admirado mentor.

En segundo lugar, a la firma Epyca Consultores por haberme permitido ser uno de los promotores de los Diálogos en Derecho Disciplinario, el gran encuentro académico que inició desde el año 2019. Se han cumplido dos eventos inolvidables, cuya calidad y significativo aporte al derecho disciplinario hace suponer que la cita anual tendrá una larga y prometedora vigencia.

En tercer lugar, al doctor William Hernández Gómez, consejero de Estado de la Sección Segunda; a los compañeros Víctor Aguirre, Sandra Marcela Gómez y Paula Andrea Gil, magistrados auxiliares; a todo el equipo de profesionales y servidores de ese despacho, y a la doctora Carolina Ramírez, mi compañera y amiga con quien hemos hecho una dupla maravillosa. Mi paso por esa corporación ha sido una experiencia inolvidable en todo sentido, por lo que mi deuda de gratitud es infinita con cada uno de ellos. Destaco muy especialmente a la doctora Paula Andrea Gil, por cuanto sin ella nada de esto hubiese sido posible y porque ha sido una generosa e incomparable maestra.

En cuarto lugar, a mis amigos y familiares más cercanos. Ellos han sido para mí un paliativo para afrontar estos tiempos tan difíciles por los que atraviesa toda la humanidad. Además, en cada conversación con ellos encuentro una lección fructífera que se incorpora automáticamente en mi continuo y muy necesario proceso de aprendizaje.

En quinto lugar, a todos aquellos estudiantes, profesionales, funcionarios, profesores, colegas y amigos que se han tomado el tiempo de leer algunos escritos y textos de mi autoría. En uno de ellos, prometí que mi paso siguiente era elaborar un trabajo relacionado con la tipicidad disciplinaria, deber académico que ha tenido que ceder, de momento, por la culminación de este proyecto. No obstante, como ocurre en el ámbito de los "deberes

funcionales", es muy probable que mi responsabilidad esté a salvo, al haber preferido el "deber de mayor importancia que el sacrificado".

En sexto y último lugar, a mi amada esposa, Diana Marcela, y a mi adorable hijo, Juan Diego. Algunos de los espacios que tenemos para compartir se han visto inevitablemente limitados, pero, gracias a su amor, apoyo, comprensión e infinita generosidad, puedo atreverme a participar en una apasionante actividad como la que está reflejada en esta obra académica.

Para mi madre, Ligia Elizabeth, quien me inculcó el valor de la disciplina. Ella no solo ha sido la mejor mamá del mundo, sino que, ahora como abuela, mi deuda impagable se sigue acrecentando. Gracias por tanto y por todo, querida y amada mamá.

JUSTIFICACIÓN DEL TRATADO 23

PRESENTACIÓN DEL TOMO I 31

TÍTULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES Y SUSTANCIALES

CAPÍTULO PRIMERO
NATURALEZA DEL DERECHO DISCIPLINARIO 35
1. Naturaleza canónica 69
2. Naturaleza civil 76
3. Naturaleza laboral 77
4. Naturaleza administrativa 78
4.1 La doctrina extranjera 78
4.1.1 Fase de la arbitrariedad 78
4.1.2 Fase moderada 79
4.1.3 Fase de la legalidad 80
4.2 La doctrina colombiana 81
4.3 Desde el ámbito de la jurisprudencia 83
5. Naturaleza penal 87
5.1 La doctrina y la jurisprudencia extranjeras 88
5.2 La doctrina colombiana 92
5.3 La jurisprudencia colombiana 94
6. Naturaleza mixta 97
6.1. La doctrina extranjera 97
6.2. La doctrina colombiana 101
6.3. La jurisprudencia 105
7. En búsqueda de su propia naturaleza 110
7.1. Problemas de admitir una u otra posición 110
7.2. La experiencia de la dogmática jurídico-penal 112
7.3. Propuestas de un derecho disciplinario autónomo e independiente 118
7.4. Derecho disciplinario y corrupción 136

CAPÍTULO SEGUNDO
ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD 141
1. Su relación con el derecho sancionador. Relaciones género a especie 141

2. El proceso de su constitucionalización 153
3. Relación con otras ramas del derecho 159
4. Relación con otras disciplinas 163
5. La relación especial de sujeción 165
6. Naturaleza autónoma e independiente 175

Capítulo tercero
La dogmática y el derecho disciplinario 189
1. Necesidad de una dogmática del derecho disciplinario 189
2. La dogmática como ciencia 195
3. La dogmática, la argumentación jurídica y el precedente judicial 205
4. Funciones de la dogmática 215
4.1. Función de garantía 215
4.2. Función constitutiva 216
4.3. Función de estabilización 217
4.4. Función de progreso 217
4.5. Función de prestación de adaptación 218
4.6. Función de descarga 218
4.7. Función de asesoramiento y mejora o función crítica 219
5. La dogmática y las diferentes expresiones de la relación especial de sujeción 220

Capítulo cuarto
La dogmática disciplinaria y sus subespecies 229
1. Dogmática disciplinaria pública: administrativa, judicial y política 229
1.1. Dogmática disciplinaria pública administrativa fundada en la relación especial de sujeción estandarizada 229
1.1.1. La practicada por los órganos de control interno disciplinario 230
1.1.2. La practicada por la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales 233
1.2. Dogmática disciplinaria pública fundada en una relación especial de sujeción intensificada por integración, por complementación o por agregación 241
1.2.1. La relación especial de sujeción intensificada por integración 241
1.2.1.1. Derecho disciplinario de las Fuerzas Militares 242
1.2.1.2. Derecho disciplinario de la Policía Nacional 244

1.2.2. La relación especial de sujeción intensificada por complementación 245
1.2.2.1. La dogmática disciplinaria judicial como una expresión específica de la relación especial de sujeción intensificada por complementación 246
1.2.3. La relación especial de sujeción intensificada por agregación de los abogados en el ejercicio profesional. Caso especial de Colombia o sistema anómalo 275
1.2.4. La dogmática disciplinaria administrativa como una expresión específica de la relación especial de sujeción intensificada por complementación 278
1.2.4.1. Relación especial de sujeción intensificada por complementación en general 278
1.2.4.2. Las dogmáticas disciplinarias aplicables a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación como expresiones específicas de la relación especial de sujeción intensificada por complementación 282
1.3. La dogmática disciplinaria pública fundada en las relaciones especiales de sujeción atenuadas 293
1.3.1. La dogmática de los particulares que ejercen "funciones públicas" 293
1.3.1.1. El alcance del concepto de *funciones públicas* 294
1.3.1.2. Cuándo un particular ejerce "funciones públicas" 296
1.3.1.3. Situaciones en las que el particular puede ser sujeto del derecho disciplinario, conforme a lo establecido en el nuevo Código General Disciplinario 308
1.3.1.4. El concepto restringido y el concepto amplio del ejercicio de "funciones públicas" en el derecho disciplinario 310
1.3.2. La dogmática de los profesores universitarios de instituciones oficiales vía autonomía universitaria 311
1.3.3. Otros modelos 316
1.4. La dogmática disciplinaria pública política 318
1.4.1. El *impeachment* 319
1.4.1.1. Presidente de la República 324
1.4.1.2. Magistrados de las altas cortes 325

1.4.1.3. Fiscal General de la Nación 326
1.4.2. La moción de censura 327
2. La dogmática disciplinaria delegada o mixta y las profesiones liberales 331
3. La dogmática disciplinaria privada 341
3.1. Empresarial 342
3.2. organizacional 344
3.2.1. Derecho disciplinario de las demás agremiaciones, asociaciones, fundaciones, fondos y demás organizaciones 348
4. La función disciplinaria como administración de justicia en sentido material y su control por la jurisdicción contenciosa administrativa 349
4.1. Decisiones de órganos administrativos de naturaleza administrativa. Actos administrativos disciplinarios 352
4.2. Decisiones de órganos de control. Actos de control disciplinarios 352
4.3 Decisiones de órganos privados de naturaleza administrativa. Actos administrativos 353
5. La función jurisdiccional disciplinaria como administración de justicia en sentido formal y material y su control único vía acción de tutela 355
6. La función política disciplinaria como expresión del control político estatal y su control único vía acción de tutela 357
7. La función disciplinaria privada como administración de justicia en sentido material 360
7.1. Su control único vía acción de tutela cuando es de tipo organizacional 360
7.2. Su control dual cuando es de tipo empresarial 366
7.2.1. Su control natural vía justicia ordinaria laboral 367
7.2.2. Su control residual vía acción de tutela 369

Capítulo quinto
La jerarquía constitucional de los principios rectores 375
1. Concepto y regencia de los principios rectores 375
2. Operatividad de su aplicación 379
3. Las reglas jurídicas como expresión de sus desarrollos 382
4. Su importancia para el entendimiento del sistema 384
5. Su valía como criterios de interpretación y/o como elementos fundacionales del sistema 386

Capítulo sexto
Principios sustanciales y procesales 393
1. Principios sustanciales 393
1.1. La dignidad de la persona como fundamento del orden jurídico disciplinario 393
1.2. El principio del derecho disciplinario de acto con sentido ético 395
1.3. El principio de la *relación especial de sujeción* 397
1.4. La norma disciplinaria como norma deontológica y directriz de conducta 400
1.5. Principios de proporcionalidad y finalidad de la sanción disciplinaria y de las normas estímulos 404
1.6. Los principios de reserva, legalidad y favorabilidad 406
1.7. El principio de contrariedad con el derecho 410
1.8. El principio de responsabilidad subjetiva 412
2. Principios procesales 414
2.1. La norma procesal como instrumento de actualización y realización del derecho disciplinario y el acceso efectivo a la administración de justicia 414
2.2. El debido proceso formal y material 416
2.3. El derecho de defensa y el subprincipio de contradicción 419
2.4. El principio de impulsión oficiosa, célere y económica 423
2.5. El principio de lealtad y buena fe 425
2.6. El principio de la doble instancia 425
3. Principios mixtos 426
3.1. *Non bis in idem* 426
3.2. Presunción de inocencia 427
3.3. Tratamiento igualitario ante la ley 428
4. Principio de autonomía e independencia 428
5. La integración como mecanismo subordinado 429

Título segundo
La estructura de la responsabilidad disciplinaria como consecuencia de la constitucionalización del derecho disciplinario

Capítulo primero
Estructura general como expresión de un derecho disciplinario único 433
1. La noción de categoría dogmática como especie 433

2. Las subcategorías dogmáticas como subespecies 443
3. El ilícito disciplinario como supraespecie 444
4. El resultado como condición objetiva de punibilidad 460
5. Favorabilidad y *non bis in idem* 461

Capítulo segundo
Las categorías y subcategorías de la responsabilidad 467
1. Capacidad de comprensión del deber como capacidad disciplinaria 467
2. Conducta 477
3. Tipicidad 485
3.1. Tipicidad de las faltas de simple omisión del cumplimiento del deber dolosas 509
3.1.1. Tipo objetivo de las faltas de simple omisión del cumplimiento del deber 510
3.1.1.1. Autor por omisión directo 510
3.1.1.2. Modalidad de situación típica circunstanciada 514
3.1.1.3. Deber jurídico en concreto incumplido 518
3.1.2. Tipo subjetivo de las faltas de simple omisión del cumplimiento del deber 527
3.1.2.1. Consciencia de la modalidad de la situación típica circunstanciada 536
3.1.2.2. Consciencia de la capacidad individual de acción del obligado en la situación concreta de activación del deber 540
3.2. Tipicidad de las faltas complejas por omisión del cumplimiento del deber dolosas 541
3.2.1. Tipo objetivo de las faltas complejas por omisión del cumplimiento del deber 542
3.2.1.1. Autor por omisión indirecto 542
3.2.1.2. Modalidad de la situación típica circunstanciada 543
3.2.1.3. Deber jurídico en concreto incumplido fundado en la obligación de controlar, inspeccionar o vigilar la actividad de otro sujeto obligado que produce un acto o una situación antijurídica 544
3.2.1.4. Capacidad individual de acción del obligado en la situación concreta que activa el deber 547
3.2.2. Tipo subjetivo de las faltas complejas por omisión del cumplimiento del deber 549

3.2.2.1. Consciencia de la modalidad de situación típica circunstanciada 549
3.2.2.2. Consciencia de la capacidad individual de acción del obligado en la situación concreta de activación del deber 549
3.3. Faltas disciplinarias culposas y la infracción al deber objetivo de cuidado 550
3.3.1. Faltas culposas de simple omisión del cumplimiento del deber 554
3.3.2. Faltas culposas complejas por omisión del cumplimiento del deber 557
3.4. Autor determinador 558
4. Ilicitud disciplinaria 561
5. Culpabilidad 575
5.1. Crítica al Código General Disciplinario por Carlos Arturo Gómez Pavajeau: ética y responsabilidad en derecho disciplinario desde la perspectiva de Max Weber 579
5.2. Defensa del Código General Disciplinario, por John Harvey Pinzón Navarrete: la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a los servidores públicos de elección popular y la culpabilidad disciplinaria: dos aspectos necesarios para la consolidación de la *autonomía e independencia* del derecho disciplinario 607
5.2.1. Introducción 607
5.2.2. Resumen de la tesis del profesor Gómez Pavajeau por la cual considera que la Procuraduría General de la Nación ya no debe seguir siendo competente para investigar a los servidores públicos de elección popular 610
5.2.3. Síntesis de la crítica del profesor Gómez Pavajeau por la redacción del dolo en el nuevo Código General Disciplinario 611
5.2.4. La Procuraduría General de la Nación es competente y debe seguir siéndolo para investigar a los servidores públicos de elección popular con el fin de que precisamente a estos se les exija más que a los simples particulares 611
5.2.5. La culpabilidad disciplinaria: los problemas de conceptualización de dolo pueden superarse con una interpretación dogmática adecuada 618
5.3. Conclusiones 623

Capítulo tercero 627
Las eximentes de responsabilidad 627
1. Eximentes de capacidad disciplinaria 627
1.1. La imposibilidad de comprender el deber normativo por trastorno mental 627
1.2. La imposibilidad de conducirse de conformidad con la comprensión del deber 627
1.3. La regla general es la exclusión de la capacidad, mientras que lo excepcional es que el fenómeno sea un asunto de culpabilidad 628
2. Eximentes de conducta 632
2.1. Caso fortuito y fuerza mayor 633
2.2. *Vis absoluta* o fuerza física irresistible 634
2.3. Eventos de inconsciencia absoluta 638
2.4. Los actos reflejos 640
2.5. Actos realizados en estados de sonambulismo o hipnotismo 640
3. Eximentes de ilicitud típica 642
3.1. Juicio axiológico 642
3.1.1. Ausencia de ilicitud sustancial 647
3.1.1.1. Falta de ilicitud sustancial por defecto normativo 647
3.1.1.2. Falta de ilicitud sustancial por contraste con la norma 648
3.1.1.3. Nimia ilicitud disciplinaria 650
3.1.2. Adecuación funcional o profesional 651
3.1.3. Conductas deontológicamente neutras 652
3.2. Juicio deontológico 653
3.2.1. Colisión de deberes funcionales con deberes funcionales 653
3.2.2. Colisión de deberes funcionales con derechos funcionales 657
3.2.3. El aspecto subjetivo de la justificante 658
3.2.4. Otros *criterios teórico-prácticos para el correcto entendimiento de la ilicitud sustancial* 659
3.3. El error de hecho 660
4. Eximentes de culpabilidad 663
4.1. Errores de hecho en materia de culpabilidad 663
4.2. Errores de derecho en materia de culpabilidad 666
4.3. Las colisiones deberes funcionales-deberes personales 668
4.4. Las colisiones deberes funcionales-derechos personales de rango legal 669
4.5. La insuperable coacción ajena o *vis compulsiva* 673

4.6. El miedo insuperable 674
4.7. Causales supralegales de inculpabilidad 680
5. Eximentes incompletas 682

TÍTULO TERCERO
LA SANCIÓN DISCIPLINARIA

CAPÍTULO PRIMERO
LA SANCIÓN DISCIPLINARIA Y SUS PRINCIPIOS GENERALES EN EL DERECHO DISCIPLINARIO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 687
1. Legalidad, finalidad, necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad 687
2. Faltas leves, graves y gravísimas 693
2.1. Sistema mixto con una participación mayor de la intervención del juez disciplinario 693
2.2. Sistema mixto con una participación menor de la intervención del juez disciplinario 694
2.2.1. Las faltas gravísimas 694
2.2.2. Faltas graves atípicas 695
2.2.3. Las faltas leves y graves 696
3. Circunstancias de agravación y atenuación 696
3.1. De agravación 697
3.1.1. Personales 698
3.1.2. Objetivas 699
3.1.3. Subjetivas 702
3.2. De atenuación 703
3.2.1. Personales 704
3.2.2. Objetivas 705
3.2.3. Subjetivas 705
4. Especificidades de las sanciones a los funcionarios judiciales 706
4.1. Sanciones graduables 706
4.1.1. Suspensión en el ejercicio de un cargo 706
4.1.2. Inhabilidad general 706
4.1.3. Inhabilidad especial 707
4.1.4. La multa como sanción de tipo pecuniario 707
4.2. Sanciones fijas 707

4.2.1. La destitución con sus especies de terminación de la relación de servicio, desvinculación del cargo y terminación del contrato de trabajo con el efecto colateral de la exclusión del escalafón de carrera 707
4.2.2. La inhabilidad de carácter permanente cuya ingraduabilidad, en principio, es jurídica (artículo 46 inciso 1.° del CDU) 707
4.2.3. La amonestación escrita, consistente en la anotación de la sanción en la hoja de vida (artículo 46 inciso final del CDU), por esencia fija 708
5. Especificidades de las sanciones a los abogados en el ejercicio profesional 708
5.1. Sanciones graduables 708
5.1.1. La multa 708
5.1.2. La suspensión en el ejercicio profesional 708
5.2. Sanciones fijas 709
5.2.1. La censura 709
5.2.2. La exclusión del ejercicio profesional 709

CAPÍTULO SEGUNDO
EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA EN EL DERECHO DISCIPLINARIO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 711
1. La ejecutoriedad y ejecutividad de la sanción 711
2. El acto de ejecución 715
3. Prescripción de la sanción 717
4. El acto de rehabilitación 718
5. Favorabilidad 720

CAPÍTULO TERCERO
LAS SANCIONES EN EL DERECHO DISCIPLINARIO DELEGADO Y/O MIXTO 721
1. Aplicación de los principios y de las normas generales del derecho disciplinario público administrativo y judicial 723
2. Criterios basados en la necesidad y atención de sus normas especiales 727

CAPÍTULO CUARTO
LAS SANCIONES EN EL DERECHO DISCIPLINARIO POLÍTICO 747
1. Aplicación de los principios y de las normas generales del derecho disciplinario público administrativo y judicial 747
2. Necesariedad y atención a sus normas especiales 750

Capítulo quinto
Las sanciones en el derecho disciplinario privado 751
1. Aplicación de los principios y de las normas generales del derecho disciplinario público administrativo y judicial 751
2. Necesariedad y atención a sus normas especiales 753

Capítulo sexto
Las sanciones en el Código General Disciplinario (Apéndice: comparación entre la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019) 757

Bibliografía 759

El Estado es una realidad y este existe por encima de cualquiera que sea la teoría que le dé explicación, fundando su existencia en una necesidad que, en el ámbito del Estado de Derecho, se finca en la protección de los Derechos Fundamentales a partir del pacto social[1].

Estado y Derecho estatal son, a su vez, uno presupuesto del otro. Radbruch, el gran filósofo del derecho, afirmó que el primero es el "*organismo*" y el segundo la "*organización*"[2].

Ambos son productos jurídicos; empero, la idea de organización está más ligada a la noción de "*institución*", forma jurídica que se construye a partir del presupuesto de "*medios y fines*"[3]. Como dice Bobbio, la lógica del análisis funcional en el Derecho es "la lógica de la relación medio-fin"[4].

Tal característica refulge clara, según Habermas, cuando despuntaba el germen del Estado moderno, época en la cual se abandonan las tradiciones de tipo sacro y se le comienza a utilizar como "*forma racional con arreglo a fines*"[5].

En nuestro ámbito jurídico, Vladimiro Naranjo Mesa decía que un "Estado es conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado en un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros Estados". Estamos de acuerdo con esa concepción; sin embargo, a esos cuatro elementos fundacionales debe ahora sumarse un componente esencial como lo son los derechos fundamentales.

Efectivamente, tal estructura estatal surge como mecanismo de protección de los derechos fundamentales en sus diferentes manifestaciones. Sin embargo, para el presente estudio, diametralmente es claro que también existe el derecho fundamental de los ciudadanos "a que se garanticen condiciones

---

1 Bobbio, Norberto & Bovero, Michelangelo. *Sociedad y Estado en la filosofía moderna*. Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1997.

2 Radbruch, Gustav. *Introducción a la Ciencia del Derecho*. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1930, p. 45.

3 Tal metodología jurídica siempre ha fungido, aunque inconscientemente, como el *leit motiv* de las formas jurídicas institucionales, pero fue el neokantismo el que la sustentó y fundamentó filosóficamente. Larenz, Karl. *Metodología de la Ciencia del Derecho*. Barcelona, Ariel Derecho, 1994, p. 105.

4 Bobbio, Norberto. *Contribución a la Teoría del Derecho*. Madrid, Debate, 1990, p. 272.

5 Habermas, Jürgen. *Facticidad y validez*. Valladolid, Trotta, 1998, p. 204.

de vida que vengan social, técnica y ecológicamente aseguradas en la medida en que ello fuere menester en cada caso para un disfrute en términos de igualdad de oportunidades de los derechos civiles", puntualiza Habermas.

De allí que, para el referido autor, a un concepto material de Estado Social que se comprometa y sea consecuente con la protección de los derechos fundamentales le compete "desarrollar y asegurar las instituciones jurídicas"[6].

Interesa entonces no solo la existencia del Estado como organismo, o mejor, jurídicamente hablando, como estructura, sino también con su plena funcionalidad[7].

Existe un gran consenso nutrido a partir de concepciones sociológicas, por demás ancladas en la realidad social, que indican certeramente que el Derecho es un subsistema del sistema social que, integrado a la perspectiva filosófica de la justicia como a la de un orden jurídico que se legitime plasmando en su substrato aquellas ideas y valores, cumple la función de estabilización de expectativas normativas, reconociendo la fuerza integradora de la acción comunicativa, en una sociedad compleja[8].

Así, la acción comunicativa al superar la visión de una razón práctica, centrada en y para el individuo, que buscaba orientarlo en su accionar, nutre al nuevo pensamiento jurídico de importantes elementos para el "entendimiento intersubjetivo".

Importa a ello, de manera significativa, el redescubrimiento de una noción de dignidad dinámica, en la cual se "*descentraliza* el reino de lo inteligible" y lo científico se aterriza en una "búsqueda cooperativa de la verdad"[9], aspecto que influye decisivamente en la consideración de la dogmática como ciencia.

También para nuestra disciplina, resulta relevante la idea de Habermas acerca del "*vacío de solidaridad*" que presentan las teorías clásicas, habida

---

6 Habermas, ob. cit., pp. 153 y 189.

7 El discurso jurídico de actualidad se desenvuelve, en el ámbito de la filosofía analítica, precursores modernos de la metodología dogmática, a partir de las nociones de "Teoría estructural del derecho" y "Teoría funcional del derecho", con un creciente interés por esta última; Bobbio, *Contribución*…, pp. 255 y ss.

8 Habermas, ob. cit., pp. 64, 69, 134, 148 y 149. También, haciendo énfasis en que una teoría jurídica es insuficiente, como lo es igualmente una teoría sociológica, estimándose entonces al Derecho "como subsistema del sistema social considerado en su globalidad". Bobbio, *Contribución*…, cit., pp. 256 y 269.

9 Habermas, ob. cit., pp. 65, 78 y 80.

cuenta de que estas perfilaban un tipo de derechos subjetivos "cortados a la medida de la acción orientada al éxito"[10].

Parece extraño hablar del principio de solidaridad en materia de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos; empero, no se puede desconocer que el primer llamado a cumplir con los mandatos de prestación es el Estado. Por tanto, los primeros obligados son los representantes de dicha organización jurídica y política, que se traduce en aquellos agentes que actúan en nombre del Estado. No en vano desde las discusiones primeras sobre el origen del Estado se han planteado vínculos de solidaridad que explican la relación jurídica funcionario-función.

Hermann Heller ya había destacado la importancia, en la concepción de Estado, del principio de solidaridad, anclando su fundamento en el ámbito sociológico, manifestando que la solidaridad tiene nacimiento en una primera época como "solidaridad territorial" generada por el sedentarismo, producto de la vecindad de pueblos que "hace precisa una unidad de acción para la protección de este espacio, así como para su eventual ampliación". Esto origina un alto grado de permanencia y densidad de las relaciones de intercambio e interdependencia, incubándose y desarrollándose en ellas la solidaridad social. Califica a dichas relaciones de interdependencia como "funciones sociales", precisando que estas "nacen y se mantienen exclusivamente mediante actos de voluntad humana socialmente eficaces"[11].

Sin duda, Heller se refiere allí tanto a los servidores públicos como a particulares; empero, es a los primeros a quienes más vincula la solidaridad social con la pervivencia misma del Estado, diríamos también que con su funcionalidad.

El Derecho tiene la "función primaria de regular los comportamientos" humanos, esto es, "de condicionar el comportamiento de los pertenecientes a un determinado grupo social"[12], función que por supuesto también cumple el Derecho Disciplinario, instituto jurídico que tiene la función esencial de *dirigir la conducta* de los servidores públicos y los particulares que ejercen funciones públicas en el marco de los principios de moralidad administra-

---

10 Habermas, ob. cit., p. 95.

11 Heller, Hermann. *Teoría del Estado*. México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 219 y 220.

12 Bobbio. *Contribución*…, cit., pp. 268 y 274.

tiva, neutralidad política, objetividad, eficacia y eficiencia (artículo 209 de la Carta Política).

Ello lo hace, lo debe y tiene que hacer en el marco de una "moral intersubjetiva", captada a partir de la Carta Política, que trascienda a una "ética de lo público".

Para lograr tal cometido, utiliza los mecanismos tradicionales y modernos de la *sanción jurídica*, entendida esta como la adjudicación de efectos de tal índole a un comportamiento, en su más acabado sentido de sanción o premio (artículo 6 del Código Civil). Esta última es característica definitoria de la noción de Estado Social, según anota Bobbio, para efecto de ir mucho más allá de las meras sanciones represivas, para dar cabida a las sanciones estímulos[13], que, como tales, también deben cumplir una destacada labor en la función de direccionamiento de conductas oficiales que cumple el Derecho Disciplinario.

El sistema sancionatorio del Estado es complejo y se encuentra multiformado, dependiendo cada especie de la funcionalidad que cumple, por lo que el cometido es precisar, describiendo sí, pero esencialmente valorando, lo que le corresponde por la forma y el contenido al Derecho Disciplinario.

No obstante, el espectro del Derecho Disciplinario es muy amplio, rompiendo incluso las tradicionales formas de análisis a partir de las categorías de derecho público y privado[14]. Ello tiene que ser así, por cuanto la estructura del Estado es compleja y amplia, por lo cual estamos ante una variedad de agentes estatales que cumplen diferentes funciones y actividades.

De la misma manera, al lado de esos diversos agentes estatales, existen diferentes controles; empero, la jurisprudencia, en especial la constitucional, ha sido partidaria de que se construya un Derecho Disciplinario Único, con el fin de que en una sola área se expliquen los fundamentos que legitiman al Estado para imponer todo tipo de correctivos, lo cual se constituyó en una línea jurisprudencial muy temprana que aparece con la Sentencia C-417 de 1993 y se consolida con la T-276 de 2014.

Tal forma de ver las cosas impone la necesidad de estudiar no solo la naturaleza del Derecho Disciplinario, su dogmática y el tratamiento especializado de sus principios rectores sustanciales y procesales, sino todas las

---

13 Bobbio, *Contribución*…, cit., pp. 371 y ss.

14 En vía prospectiva, Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *Dogmática del Derecho Disciplinario*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 200 y ss.

expresiones de derecho sancionador que tienen como elemento común la teoría constitucional de las Relaciones Especiales de Sujeción. De allí podemos extraer toda la justificación y su respectiva dogmática, para que sea incorporada en un Derecho Disciplinario Único que sea capaz de explicar todo su alcance y contenido en los distintos ámbitos fácticos y jurídicos de todo aquel que actúe en representación y por cuenta del Estado.

Recordemos que, al despuntar el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, la disciplina que se encontraba regida por la llamada "teoría clásica" de la "relación especial de sujeción" estaba imbuida en una especie de discrecionalidad –manejada a partir de los principios de conveniencia y oportunidad propios del antiguo Derecho Administrativo– y en no pocas ocasiones desembocaba en arbitrariedad.

Volenti non fit inuria era el axioma que regía a la teoría de la "relación especial de sujeción", lo cual traducía que quien ha dado su voluntad no puede sufrir perjuicio.

Los derechos subjetivos, por su misma definición, eran enajenables y transferibles, valían en el ámbito del interés individual, concernían exclusivamente al sujeto y este, en razón de ello, tenía pleno gobierno en su propio ámbito de dominio.

La prevención contra toda medida paternalista en cabeza del Estado y la confianza acerca de que la voluntad, como expresión de la racionalidad, contribuía al progreso social, en tanto lo importante era que el individuo decidiera libremente –no en particular lo que decidiera–, produjeron unos efectos totalmente contrarios en el sistema de garantías, pues estas se dejaban de lado cuando el sujeto accedía al servicio público, toda vez que aceptaba el cargo con todas sus virtudes, pero también con todas sus vicisitudes, habida cuenta de que el acto legal y reglamentario del nombramiento no se negociaba; por el contrario, se constituía en un verdadero acto jurídico de adhesión.

El Derecho Disciplinario, cual náufrago en alta mar, para salvar su existencia, se apegó a lo que podía sustentarlo, al Derecho Penal, puesto que ante la nueva visión constitucional los derechos fundamentales universales y atemporales resultaban innegociables e intransferibles, y por demás inenajenables.

Se comenzó a decir que la falta disciplinaria se constituía a partir de la realización de una conducta típica, antijurídica y culpable, verdadero punto de inflexión en su evolución doctrinal.

En nuestro medio, vale la pena recordar la sentencia de 14 de abril de 1983, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, según la cual al Derecho Disciplinario le resultaban aplicables las garantías sustanciales y procesales que se predicaban del Derecho Penal.

Derecho Penal y Derecho Disciplinario eran una misma cosa; la teoría se transportaba acríticamente desde aquel hacia este, con lo cual, guardando el símil con lo que sucede entre siameses que comparten órganos, la sangre del primero se bombeaba hacia el segundo, creando así respecto de nuestra disciplina una profunda dependencia, con lo cual se producía una "total y mecánica transposición de elaboración penal y primariamente penalista"[15].

Pero tal traslado no ha sido completamente beneficioso, aunque importante en su momento como cambio de paradigma, puesto que, como dice Parejo Alfonso, el "proceso de acomodación del Derecho administrativo sancionador al Derecho penal ha permitido ciertamente reconducir a esquema la potestad sancionadora de la Administración, con paralela y consecuente elevación de las garantías de los ciudadanos", pero no ha "podido evitar, sin embargo, la aparición de no pocas perturbaciones en el funcionamiento real del instrumento sancionador", por cuanto "la traducción radical al campo administrativo sancionador de los principios del Derecho penal [...] se ha mostrado en ocasiones incompatible con el cumplimiento de los fines de la actividad administrativa"[16].

De allí que Rubio Llorente haya demandado la necesidad de una "construcción dogmática" del derecho disciplinario, la cual debe ser configurada "en términos que resulten compatibles con los principios básicos del Estado de Derecho, que la Constitución también consagra"[17].

Pero no puede negarse que un efecto positivo de tal movimiento ha producido la idea de que el Derecho Disciplinario es una función "materialmente judicial" y, por tanto, comporta una "evolución garantista y jurisdiccionalizadora"[18], lo que en nuestro medio ha reconocido la Corte Constitucional en sus sentencias C-014 de 2004, SU-901 de 2005 y T-350 de 2011, en las cuales se afirma que incluso, en el Derecho Disciplinario

---

15 Domínguez Vila, Antonio. *Constitución y Derecho Sancionador Administrativo*. Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 199.

16 Prólogo al libro de Domínguez Vila, cit., p. 12.

17 Rubio Llorente, Francisco. *La forma del poder*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 349.

18 Domínguez Vila, ob. cit., p. 19.

Administrativo, sus autoridades administran justicia en sentido material, lo que inmediatamente conlleva reclamar la aplicación de los artículos 1, 4, 85, 86, 93, 94, 228, 229 y 230 de la Carta Política a los procesos disciplinarios cualquiera que ellos sean y la naturaleza que se esgrima para calificarlos, lo cual aterriza en la constitucionalización y convencionalización del Derecho Disciplinario, por encima de toda teoría que se exponga sobre el mismo, o lo que en otras palabras podemos calificar como la metateoría disciplinarista del Derecho.

Por virtud de ello, hoy se afirma que el derecho disciplinario "formula una imputación que se basa en la infracción de deberes funcionales y en el que se aplican los principios que regulan el derecho sancionador como los de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, responsabilidad, proporcionalidad y *non bis in idem*, pero, desde luego, con las matizaciones impuestas por su específica naturaleza"[19].

El camino recorrido en los últimos años por el Derecho Disciplinario muestra un muy importante desarrollo de su dogmática, cumpliendo un papel trascendental en ello el trabajo de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No obstante, parece que algunas jurisprudencias de la jurisdicción contenciosa administrativa se construyeran a espaldas de todo ese saber, imperando un voluntarismo judicial en materia de interpretación y aplicación de la ley disciplinaria que augura muy malos presagios, pues cada juez administrativo sienta su propia y subjetiva doctrina *ad hoc,* sin que exista un mecanismo en la cúspide de dicha jurisdicción que unifique la interpretación de la ley a escala nacional, por lo que se siembra el desconcierto en los operadores jurídicos disciplinarios[20] –muy especialmente es visible esto en el Consejo de Estado respecto de los argumentos utilizados para fundar la culpabilidad en las salas especiales de pérdida de investidura respecto de lo afirmado por las salas que se ocupan del control de los actos administrativos sancionatorios en materia laboral administrativa–, con lo cual se comienza a desandar el camino recorrido. Ahora bien, si a esto se le suma la indeseable presencia de factores extrajurídicos –políticos, para ser más claros– en algunas decisiones trascendentales, una acentuada e inconveniente inseguridad jurídica se irá acrecentando, generándose caos, confusión y de

19 Sentencias C-252 de 2003 y C-014 de 2004.

20 En nuestro trabajo *Elementos y propuestas para el control contencioso administrativo de la actividad disciplinaria*, 2009, hemos expuesto dicha problemática.

manera lamentable impunidad, lo que solo se visibiliza como superable con la constitucionalización y convencionalización del Derecho Disciplinario como *disciplina única*.

De manera tal que la esperanza por los avances de un Derecho Disciplinario autónomo e independiente, no tributario del Derecho Penal y mucho menos calificado como su apéndice, lo cual ha llevado a que algunos doctrinantes lo motejen como un derecho penal en miniatura[21], es un anhelo y estado ideal que entre todos debemos construir.

Igualmente, no menos importante, y sí bastante útil y rendidor, es intentar construir un Derecho Disciplinario Único, el cual contenga la fundamentación de todos los tipos de controles que se derivan de la categoría constitucional de la Relación Especial de Sujeción.

Pero, además, la unificación de la jurisprudencia nacional, el papel de los abogados que litigan en disciplinario, las autoridades que ejercen función y muy especialmente la doctrina, tienen la enorme tarea y responsabilidad de formar un derecho disciplinario autónomo e independiente, capaz de aliviar los males de la corrupción y de la ineficiencia administrativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que este estudio integral del derecho disciplinario jugará un papel trascendental para alcanzar los propósitos antedichos. Ello tiene que ser así porque todo aquel que actué en representación y por cuenta del Estado tiene una enorme responsabilidad, en la medida en que su funcionalidad está dada para el beneficio de la misma Sociedad.

---

21 Así, Rojas Caro, José. *Derecho Disciplinario Militar*. Madrid, Tecnos, 1990, p. 62.

El presente tomo, compuesto por tres títulos, es la primera parte del estudio integral del Derecho Disciplinario.

En el Título primero ofreceremos una visión introductoria sobre el Derecho Disciplinario tanto en sus aspectos generales como sustanciales.

Para ello, un presupuesto necesario será el estudio de la naturaleza del derecho disciplinario, su estructura y funcionalidad, su relación con el derecho sancionador, su proceso de constitucionalización, su relación con otras ramas del derecho y en especial su dogmática, dilucidando sus reglas, la importancia de estas y sus repercusiones en la construcción doctrinaria de la materia.

Tan importante resultará lo anterior que a partir de allí tendremos los fundamentos para proponer todas las subespecies de la Dogmática Disciplinaria, dándoles sentido a otras expresiones de derecho disciplinario que tienen fundamento en las diversas clases de las Relaciones Especiales de Sujeción que existen en el ámbito jurídico colombiano. Todo ese esfuerzo quedará completo cuando desarrollemos los aspectos teóricos de los principios rectores, tanto sustanciales como procesales, aplicables a todas las diversas clases del derecho sancionador o, como queremos proponerlo desde ya, de un Derecho Disciplinario Único, que cuando menos está en proceso de construcción.

En un Título segundo, elaboraremos una propuesta dogmática del estudio del derecho sustancial, para lo cual nos referiremos a la estructura de la responsabilidad disciplinaria, insistiendo en la necesidad de un Derecho Disciplinario Único. Obviamente, para cumplir tan importantes cometidos, tendremos que referirnos a los conceptos básicos de lo que significa la dogmática, bien entendida como método o como ciencia, y a lo que podríamos denominar como el núcleo "duro" del derecho disciplinario sustancial, esto es, las categorías que componen la estructura de la responsabilidad. En tal forma, haremos las reflexiones en cuanto a la capacidad, la conducta, la tipicidad, la ilicitud sustancial y a la culpabilidad. De la misma manera, se planteará el estudio de las eximentes de responsabilidad, toda vez que pareciera que hoy en día el contenido material de las categorías y subcategorías no viene definido de manera positiva, sino negativa, a partir de las fórmulas jurídicas que consagran su exclusión.

Finalmente, en el Título tercero de esta primera entrega tendrá cabida el desarrollo dogmático de la teoría de la sanción disciplinaria. Allí se abordará

lo referente a los principios que la gobiernan, su forma de ejecución y su proporcionalidad de todas las manifestaciones del Derecho Disciplinario precedentemente estudiadas.

Los anteriores aspectos, contenidos en tres títulos totalmente diferenciados, son a nuestro juicio los temas más significativos para el correcto entendimiento del derecho disciplinario sustancial en su integridad.

Por ello, en el tomo II quedarán diferidos los aspectos procesales.

TÍTULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES Y SUSTANCIALES

CAPÍTULO PRIMERO
NATURALEZA DEL DERECHO DISCIPLINARIO

En el texto *Dogmática del Derecho Disciplinario* se ha dicho, acerca de la naturaleza del Derecho Disciplinario, que podría haber tres doctrinas que explican el fundamento de esta importante rama del derecho. No obstante, los constantes cambios, las realidades sociales y los importantes aportes de la jurisprudencia hacen que podamos ensanchar las teorías explicativas de esta especial disciplina. Por tanto, analicemos cada una de estas concepciones, sin perder de vista que el objetivo final será seguir defendiendo una sola con carácter de autónoma e independiente.

No se trata de reducir a un pretendido absurdo una u otra posición. Creemos sinceramente que cada una de ellas aporta al entendimiento de lo que hoy se aprecia por Derecho Disciplinario desde una perspectiva autónoma e independiente, la cual se adquiere por la identidad que sus diferentes manifestaciones le otorgan en el orden jurídico colombiano, por supuesto muy diferente al de otras latitudes donde, muy seguramente, encontrarán ciertas teorías apego a la realidad ofrecida, lo que es imposible de hallar en las multiformas o multidimensionalidad del Derecho Disciplinario colombiano, que como tal demanda una respuesta coherente y sólida que la explique, no como colcha de retazos o calificando como anómalo o excepcional[22] aquello que no encaja en la visión ofrecida por cultores internacionales que, por muy distinguidos que sean, escriben sobre lo que ofrecen sus propias realidades, sin que ello nos restrinja o quite el derecho de opinar en contra o de manera diferente, o si se quiere, de manera complementaria a como ellos lo han hecho.

Se afirma que con nuestras posturas se incurre en "*imprecisiones metodológicas*" y por supuesto confundimos "*diferencias normativas con diferencias ontológicas*" o se acude "*a las instituciones jurídicas, simplemente dando por sentado lo que se ha dicho en el pasado*"[23].

Lo primero que debe advertirse es que no fuimos nosotros quienes dimos por sentada la pretensión de la existencia de un Derecho Disciplinario autónomo e independiente; creemos que ello surge como una necesidad

---

22 *Cfr*. Rincón Córdoba, Jorge Iván. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo.* Buenos Aires, Universidad de Piura e IJ Editores Información Jurídica, 2018, p. 69.

23 Rojas López, Juan Gabriel. *Derecho administrativo sancionador. Entre el control social y la protección de los derechos fundamentales.* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020, p. 135.

ofrecida por la regulación del fenómeno a partir de lo que indica la Carta Política, por lo que, antes que perdernos en chauvinistas discusiones, debe decirse que dicha propuesta es obra de la constitucionalización del derecho, producto de la consideración de la Constitución como "*norma que norma* o *norma normatae*" –así sucedió en una época con todas las ramas del Derecho en un sistema de Derecho Natural Teológico, antes del cambio de paradigma que significó el advenimiento del constitucionalismo moderno–, de la aplicación directa de las normas constitucionales como fuentes del Derecho de inmediato reconocimiento, de los efectos irradiantes de los derechos fundamentales constitucionales y de la configuración de sus diferentes ramas a partir de ellos, de los principios y valores constitucionales que hacen parte de los Principios Fundamentales del Estado y de la llamada Parte Dogmática o Filosófica de la Constitución (artículos 1, 2, 4, 29, 85, 86, 93, 94 y 228)[24].

La denominación "*Derecho Disciplinario autónomo e independiente*" no es un capricho o expresión pretensiosa nuestra[25-26]; calificado también como propuesta de "*pseudoautonomía*"[27], viene tomada de quien la acuñó, pues aparece en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que se convertiría posteriormente en la Ley 200 de 1995, por lo que se puede afirmar que tuvo como inspiración la propuesta del para entonces Procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta Padilla[28], el verdadero gestor de la

---

24 Así, Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. "Principios Rectores y Derecho Disciplinario en Colombia", en *Fundamentos de Derecho Disciplinario colombiano.* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 23 y ss.

25 En contra, por todos, Rojas López, Juan Gabriel. "La antijuridicidad material: ¿elemento de la potestad sancionadora de la Administración?", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Alberto Montaña Plata & Jorge Iván Rincón Córdoba (editores), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 193 y ss.

26 Para el efecto, Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. "Aspectos decisivos que determinaron, determinan y determinarán la evolución del Derecho Disciplinario en Colombia", en *Fundamentos de Derecho Disciplinario colombiano*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 214 y ss.

27 Así, Ospina Garzón, Andrés Fernando. "El fundamento del poder de sanción de la Administración: terapia para el abandono de un complejo", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Alberto Montaña Plata & Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 36 y ss.

28 Fue absolutamente claro y convincente en proponer un proyecto de ley que concibiera al Derecho Disciplinario como "una superfunción, regido por una filosofía y contenidos propios", puesto que "es incuestionable que la Constitución de 1991 abrió las puertas para la consolidación de un

expresión, reiterada por Edgardo José Maya Villazón como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura cuando, como presidente, encabezó una Comisión Redactora que propuso un Código Disciplinario Jurisdiccional –funcionarios judiciales y abogados en el ejercicio de la profesión–, como se puede apreciar por las múltiples menciones que al mismo texto hemos realizado en nuestros escritos, incluido este, de lo cual fuimos entusiastas desde un principio y aspiramos a serlo hasta el final de nuestras vidas académicas, si no nos convencen de lo contrario.

Precisamente, tal planteamiento fue también tema de inspiración de la Ley 734 de 2002, en palabras de su impulsor, el para entonces Procurador General de la Nación Jaime Bernal Cuéllar[29].

Y hablamos de ciencia del Derecho Disciplinario, en el marco mismo de lo que se entiende por tal en el concierto de la Metodología Dogmática[30], impregnada de la filosofía[31] y presidida por la metadisciplina de la neuroantropología filosófica[32], cuyas reglas seguimos muy conscientes de que no existen verdades inconcusas y perennes, solo lo son mientras una refutación

---

nuevo y autónomo derecho. El Disciplinario … para fijar postulados que bien pueden fundamentar una teoría propia de la responsabilidad disciplinaria, partiendo de la función y fines del Estado … [estableciendo su objeto que es] la conducta funcional … con un aparato único de control disciplinario [bajo] unidad conceptual … [generando] una visión clara de su naturaleza y alcance … [donde impere] la interpretación teleológica y sistemática … [por una elaboración por la doctrina] de una teoría tendiente a establecer un derecho con autónomos principios y singulares finalidades", calificando al Derecho Disciplinario como una "rama indiscutible del derecho": *Gaceta del Congreso*, Senado y Cámara, año II, n.° 31, del 9 de marzo de 1993. Bogotá, Imprenta Nacional, pp. 10, 11, 12 y 13.

29 Jaime Bernal Cuéllar. *Proyecto de Código Disciplinario Único*. Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 1999, p. 22, y *Gaceta del Congreso*, n.° 263, de junio 4 de 2001, p. 4.

30 Claus-Wilhelm Canaris. *El sistema en la jurisprudencia*, Juan Antonio García Amado (trad.). Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1998.

31 Sobre el carácter científico de las ciencias del espíritu, sociales, culturales, en fin, humanas, de gran impacto en la Dogmática como ciencia en una primera aproximación con el neokantismo y actualmente en boga con el derecho penal posfinalista o "síntesis neoclásico-finalismo", ver Köhnke, Klaus Christian. *Surgimiento y auge del neokantismo. La filosofía universitaria alemana entre el idealismo y el positivismo*, José Andrés Ancona Quiroz (trad.). México, Universidad Autónoma Metropolitana y Fondo de Cultura Económica, 2011, y Borja Jiménez, Emiliano. "Algunos planteamientos dogmáticos en la teoría jurídica del delito en Alemania, Italia y España", en *Nuevo Foro Penal*, n.° 59, año X, enero-marzo 1993. Bogotá, Temis, 1993, pp. 24 y ss.

32 Valle Oñate, Rafael; Gómez Pavajeau, Carlos Arturo & Gutiérrez de Piñeres Botero, Carolina (dirs.), *Opúsculos de neuroantropología filosófica*, tomo I: *La materia prima del Derecho Penal y Disciplinario. Razón, emoción y el dilema libre albedrío-determinismo de la conducta humana desde las perspectivas del inconsciente y la consciencia*. Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 2019, pp. 25 y ss. y 1033 y ss.

proponga algo mejor[33]. Uno de nosotros se ha ocupado a fondo sobre el tema de la "*antijuridicidad material*"[34]; no obstante, somos conscientes que si esta categoría se predica también para el Derecho Disciplinario y, como lo propone Rojas López para todo el Derecho Sancionador Administrativo, en un ejercicio extremo de positivismo legalista y esgrimiendo jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero guardando silencio de lo que dicen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado[35], no solo vamos a tener una clonación de regímenes sancionatorios, sino que la racionalidad de cada uno de ellos se pierde, pues sus finalidades serían las mismas, sin que dicha diferenciación como lo proponemos rebaje un ápice las garantías de las personas destinatarias de los mismos[36].

Desde muy temprano, en otros de nuestros escritos, en coautoría con Gerardo Barbosa Castillo, identificamos un potencial genuinamente colombiano en la metodología con la cual se puede abordar el estudio de los fenómenos jurídicos, algo que involucraba o presuponía como antecedente el estudio de las "*estructuras lógico-objetivas*" de Hans Welzel o la "*naturaleza de la cosa*" de Gustav Radbruch, como criterios que permitieran superar la arbitrariedad estatal esbozada entre los años de 1933 y 1945 en el seno del nacionalsocialismo alemán, tomando partido por lo que el constitucionalismo moderno significó para el renacimiento de las ruinas del guerra en la Europa de mitad del siglo XX, pensamiento enarbolado muy especialmente por Otto Bachof[37], al cual nos aproximamos a través de la pionera obra de filosofía jurídica colombiana que pareció preceder a los anteriores, como lo fue el intento de injertar en Kelsen el germen de lo valorativo, para evitar que la regla de la mayoría de la democracia disolviera en el nudo poder del legislador, el problema ético y de la justicia.

Echamos mano de la propuesta de Rafael Carrillo Lúquez efectuada a partir de junio 22 de 1947, quien sin duda se anticipó a la idea de constitu-

---

33 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *La dogmática como ciencia del Derecho. Sus especies: penal y disciplinaria. Necesidad, semejanzas y diferencias*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.

34 *Cfr*. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *El principio de la antijuridicidad material. Fundamentos constitucionales, doctrinales y jurisprudenciales*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020.

35 *Cfr*. Rojas López. *La antijuridicidad material: ¿elemento de la potestad sancionadora de la Administración?*, cit., p. 196.

36 Ver Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *La lucha por los derechos en el Derecho Disciplinario*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020.

37 Bachof, Otto. *Constitución y jueces*. Madrid, Civitas, 1985.

cionalización del Derecho[38], y a quien se le reconoce como el Padre de la Filosofía Moderna en Colombia y con toda seguridad de la Filosofía Jurídica, quien por obra de un método que superaba las "*estructuras lógico-objetivas*" welzelianas, que si bien pueden con una primera mirada conducir a un materialismo o naturalismo extremo, no es así en su resultado al final, puesto que fundaba su teoría en Nicolai Hartmann, cuya propuesta ontológica está preñada de significado en tanto "*lo real no se confunde con la cosa*", siendo tan real como ellas "*las ocupaciones, el trabajo, las acciones, en una palabra, el destino de lo humano*" y por supuesto los "*procesos psíquico-espirituales*", en palabras de Emilio Estiú su prologuista, quien lo extrae del nuevo concepto de realidad esbozado por aquel[39].

Por ello, Welzel calificaría a su súper "*estructura lógica-objetiva*" de la autonomía ética de la persona, que identifica con lo que las constituciones modernas denominan "*dignidad de la persona*", la capacidad para orientarse por el sentido, por el valor y por la verdad como el mayor instrumento de la limitación del poder, única capaz de hacerlo inválido, muy a pesar de que el grueso arsenal de las demás categorías filosóficas no tuvieran esa aptitud, pero que, si entendemos que los derechos humanos más importantes son emanaciones de aquella, los más cercanos al núcleo esencial de la dignidad, ningún obstáculo se presentaría para afirmar que Welzel también fue un gran precursor de la constitucionalización del Derecho.

El punto de encuentro reside en la propuesta de Rafael Carrillo, quien, a partir de una reinterpretación de Kelsen, enlaza las estructuras lógico-objetivas welzelianas con el poder de constitucionalización del derecho, al postular la existencia de lo que nosotros hemos denominado, inspirados en Juan Fernández Carrasquilla, "*estructuras lógico-objetivas-valorativas*" con pleno entendimiento del papel de los Derechos Humanos en la construcción de un nuevo Derecho, que tendría como punto de inflexión la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948[40], criterios ya anunciados por Rafael Carrillo en 1945 con su escrito sobre "Filosofía del Derecho

---

38 Carrillo Lúquez, Rafael. *Ambiente axiológico de la teoría pura del Derecho*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1979.

39 Hartmann, Nicolai. *La nueva ontología*, Emilio Estiú (trad.). Buenos Aires, Suramericana, 1954, pp. 43, 45, 75 y 100 y ss.

40 *Cfr*. Barbosa Castillo, Gerardo y Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *Bien jurídico y derechos fundamentales. Sobre un concepto de bien jurídico para Colombia*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 27 y 28.

como filosofía de la persona", donde se afirma que, para poder estimar el Derecho en su esencia, se exige que sea tratado "*como intermediario entre la persona y los valores, lo que implica ya un papel preponderante de las aspiraciones humanas*", cuya teleología implicaba que debía ser encontrado "*realizando una integración de la ontología –término con el cual se designa a lo lógico– y la axiología jurídicas*"[41].

El valor, que está más allá de la norma suprema que es la Constitución, le imprime a esta su sentido axiológico, creando un sistema que direcciona en tal sentido la interpretación y aplicación de la norma jurídica. La norma jurídica, para la época en que escribió Carrillo Lúquez, daba cuenta en términos del positivismo jurídico legalista de un supuesto de hecho y otro de derecho, a partir de lo cual funcionaban los conceptos de "*relación proposicional lógico-conceptual*" o "*relación proposicional lógico-imputativa*", que en términos de equivalencia se correspondería con lo que modernamente se conoce como "*normas reglas*". Pero también afirma que, si estas normas valen en tanto pertenecientes al sistema positivo, otras no consignadas por este también valen[42], lo que sin duda alguna anticipaba el contenido de lo que es hoy el artículo 94 de la Carta Política, según el cual la inexistencia de regulación positiva de derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana no será óbice para reconocerlos, lo que ratifica el literal c) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos en armonía con el artículo 93 de la Carta Política.

Y ello es así en tanto la norma "es un esquema de interpretación", por lo que "irradia sentido jurídico sobre la situación de hecho que es una determinada conducta humana", por lo que todo acto y acción humana están referidos "*a norma y valor*", con sentido jurídico dado su "sentido objetivo, que recibe en última instancia de la norma suprema, fuente de toda juridicidad"[43].

Todo valor proviene de la comunidad y de ello da cuenta la filosofía del derecho, de manera que "norma originaria y valor coinciden", es una "instancia metajurídica" donde norma y valor se equiparan[44], lo que en términos

---

41 Carrillo Lúquez, Rafael. "Filosofía del Derecho como filosofía de la persona", en *La filosofía en Colombia. Siglo xx*. Bogotá, Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, 1985, pp. 25, 37 y 38.

42 *Cfr*. Carrillo Lúquez. *Ambiente axiológico de la teoría pura del Derecho*, cit., pp. 63, 70 y 71.

43 *Ibid*., pp. 71 y 72.

44 *Ibid.,* pp. 71 y 81.

modernos significa que los valores constitucionales son normas, valen en cuanto tales, en cuanto y tanto la Constitución es "*norma de normas o norma que norma*", según sus artículos 1, 2 y 4 de la Carta Política.

Si ello es así, entonces, como dice Carrillo Lúquez, "cuando se nos dan los valores, lo hacen viniendo acompañados de un deber ser realizados", toda vez que "el deber ser es una relación adherida al valor y a la norma originaria, transmitiéndose de la norma originaria al resto del ordenamiento jurídico positivo", debiendo el juez, en cuanto hombre, captarlo inteligentemente y realizarlo, habida cuenta de que se hace imperativo por virtud de "la conexión en que se encuentran las *relaciones proposicionales lógico-imputativas* y las *relaciones proposicionales lógico-axiológicas*"[45], lo que muestra la relación hoy existente entre *normas-regla* y *normas-principio*[46] a las cuales equivalen, respectivamente, los dos tipos de proposiciones antes mencionadas por el filósofo vallenato.

De allí que diga, por supuesto partiendo de una ontologización de los valores, que "el ser en sí, es, pues, una característica común de la norma originaria y el valor"[47], esto es, de los principios, valores y derechos constitucionales fundamentales y de las normas que componen el ordenamiento jurídico positivo, particularmente de aquellos provenientes del Orden Público Internacional de los Derechos Humanos, como cometidos de los jueces de la República[48].

He allí nuestra forma de pensar, centrados en el entendimiento de la problemática en el ámbito de la constitucionalización y convencionalización del Derecho, propuesta que enlaza con las valoraciones de lo nacional y lo internacional, impregnadas en los Derechos Humanos, que demanda un juicio comparativo y ponderativo de los mismos, al tenor de los artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

---

45 *Ibid*., pp. 76, 77 y 83.

46 Para el efecto, Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. "Principios rectores y Derecho Disciplinario en Colombia", en *Revista Brasileira de Estudos da Função Pública*, año 1 n.° 1. Brasil, Editora Fórum.

47 *Cfr*. Carrillo Lúquez, ob. cit., *Ambiente axiológico de la teoría pura del Derecho,* p. 75.

48 Para el efecto, Ordóñez Solís, David. *Jueces, derecho y política*. Navarra, Thomson-Aranzadi, 2004, pp. 32 y 91, y Gómez Pavajeau, Carlos Arturo & Otero Suárez, Iván Daniel. *El decálogo del juez como cerebro jurídico del constitucionalismo moderno. De los axiomas y silogismos fundamentales para el derecho penal y disciplinario*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.

No es cuestión de materialismo y menos de posiciones ontológicas sin sentido plantear que en Colombia, por virtud de la cláusula del libre desarrollo de la personalidad contemplada en el artículo 16 de la Carta Política, muy diferente a las alemana y española, se diga que el Derecho Penal venga prefigurado constitucionalmente, pues su injusto no puede ir más allá de exigencia legitimantes de la intervención, que lo son en conjunción inescindible como puede predicarse de la afectación de los derechos de los demás y el orden jurídico, donde por supuesto la diferencia entre la *ultima ratio* y la "*penúltima ratio*" no puede ser cuantitativa o de grado, sino de esencia o cualidad, imposible de aceptar al admitir otros ordenamientos constitucionales a modelos de Derecho Penal fundados en la alternativa o acumulativamente afectación de los derechos de los demás, afectación del orden jurídico o afectación de la moral.

La Corte Constitucional ha dicho que la definición de lo que es un bien jurídico no es asunto que solo y exclusivamente concierne a la ley; debe, pues, involucrarse a los principios, valores y derechos constitucionales, por lo que un tipo penal no puede ser legítimo o válido constitucionalmente hablando si no protege un valor constitucionalmente relevante (sentencias C-070 de 1996, C-335 de 2008 y C-442 de 2011).

Si ello es así, ¿puede afirmarse tan a la ligera que se ha superado el punto de la diferencia sustancial en cuanto al objeto de protección y el sentido y contenido de la antijuridicidad penal y los del Derecho Sancionador Administrativo? Ello solo sería posible si se nos permitiera un salto en el vacío, alegando de conformidad con la doctrina alemana y española que son las más citadas, despojadas de una realidad colombiana ineludible y, sobre todo, de espaldas a nuestra Constitución y al entramado que subyace al Control de Convencionalidad, constitutivos de *norma normatae* al tenor de los artículos 1, 2, 4, 85, 86, 93 y 228 de la Carta Política en armonía con los artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

¿*Será que la doctrina extranjera, vertida sobre otra normatividad, sin más ni más resulta aplicable en Colombia*? Si en España el asunto de la diferencia sustancial entre Derecho Penal y Derecho Sancionador Administrativo se encuentra agotado, también ello es así sin más ni más para Colombia, desconociendo las propias peculiaridades de cada país.

Los Derechos Humanos consagrados en tratados internacionales suscritos por Colombia pagan doble "*peaje de control previo*" antes de entrar

a regir o dárseles aplicación en Colombia, como se puede deducir sin hesitación alguna de *i)* los artículos 241 numeral 10 de la Carta Política y *ii)* 93 *ibidem* en armonía con el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La doctrina extranjera entra "como Pedro por su casa" y ni siquiera se intenta analizar mínimamente si resulta compatible con los principios, valores y derechos constitucionales fundamentales, pues ello se difiere a una mera decisión política[49].

Pues bien, si ello implica falta de metodología, inconsistencia o palabrería vana y abstracta, generalizadora, viva la crítica panfletaria como final y supuestamente sería la nuestra.

Recuérdese que lo afirmado para Alemania y España, respecto al contenido del bien jurídico y de la antijuridicidad, por ejemplo en sentencias de sus tribunales constitucionales y decisiones de tribunales internacionales de justicia, dicha indistinción o sinonimia entre lo penal y sancionador administrativo sería válida, pero no para Colombia, si nos atenemos a las valoraciones que subyacen al Control de Convencionalidad de conformidad con los artículos 4, 93 y 228 de la Carta Política en armonía con el artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos[50], puesto que nuestro Derecho se encuentra constitucionalizado y convencionalizado.

Resulta de verdad exagerado, por no decir absurdo, que se afirme que la única contención al desborde del poder creativo del legislador se encuentra para el Derecho Disciplinario en la utilización del concepto de bien jurídico, olvidándose que en Derecho Penal se contrae al "*bien jurídico penalmente tutelado*" (artículo 11 de la Ley 599 de 2000), lo que en sí comporta una contradicción con el mandato del principio rector del artículo 21 de la Ley 734 de 2002 cuando prohíbe acudir a conceptos penales incompatibles con la "*naturaleza del derecho disciplinario*", que como tal viene expuesta en la protección de los "*deberes funcionales*" de su artículo 5, puertas que abrió la Ley 200 de 1995, cuando reclamó en su exposición de motivos por el Procurador Arrieta Padilla, que el objeto del Derecho Disciplinario eran las "*conductas funcionales*", sobre todo cuando hoy se reconoce que lo anti-

---

49 Rojas López. *Derecho administrativo sancionador*, cit., p. 164.

50 Ver Barbosa Castillo & Gómez Pavajeau, ob. cit., pp. 51 y 52. También Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *El principio de antijuridicidad material. Fundamentos constitucionales, doctrinales y jurisprudenciales*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 280 y ss.

jurídico disciplinario no se entiende en términos meramente formales, sino sustanciales[51].

No puede sostenerse que la diferencia entre derecho penal y derecho administrativo sancionador es asunto de mera política criminal[52], pues esta no puede ser sino ajustada a la Carta Política, error que se advierte cuando se afirma que se pueden punir delitos de peligro abstracto, cuando estos resultan totalmente contrarios a la Carta Política y particularmente a su artículo 16, como se viene sosteniendo muy temprano por la jurisprudencia constitucional, contrario al ejemplo de otras legislaciones donde se admite, sin rubor, un derecho penal sin bien jurídico y sin principio de lesividad.

Lo expuesto por la doctrina penalística alemana debe tomarse con mucho cuidado cuando se trata de utilizar los conceptos allá esbozados bajo otras reglas constitucionales, por ejemplo, frente a la garantía al libre desarrollo de la personalidad o estatus activo de acción, donde el legislador puede crear delitos fundados en la mera desobediencia de la norma y hasta exclusivamente en la moral, temática imposible de aceptar en Colombia[53], de tal manera que no se trata de un asunto de mera política criminal como lo han entendido los administrativistas.

Por tanto, suscribimos con entusiasmo las conclusiones del excelente estudio de Derecho Comparado de Diana Restrepo Rodríguez, quien afirma la existencia de una versión constitucionalizada del bien jurídico, muy bien denominada "*mestiza*" o "*criolla*"[54], cuyas especificidades, sin abjurar de las fuentes de las cuales proviene, nos muestran un particular panorama jurídico digno de tener en cuenta, del cual además creemos haber respetado su metodología, sustancia, contexto y antecedentes.

---

51 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. "La ilicitud sustancial como un doble juicio: deontológico y axiológico", en *Fundamentos de Derecho Disciplinario colombiano*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 214 y ss.

52 Así, Rincón Córdoba, Jorge Iván. "Origen, justificación y presupuestos de la potestad sancionadora de la Administración en el ordenamiento jurídico colombiano", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Alberto Montaña Plata & Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 73 y ss.

53 *Cfr*. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. "Dogmática penal y teoría del injusto en el nuevo Código Penal", en *Estudios de Dogmática en el Código Penal de 2000*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020.

54 Restrepo Rodríguez, Diana. "Aproximación al concepto de bien jurídico en un 'Derecho penal colonizado': el caso colombiano", en *Revista Nuevo Foro Penal*, vol. 6, n.° 75, julio-diciembre 2010, pp. 131-193. Medellín, Universidad Eafit.

Nunca hemos pretendido ni pretendemos entender, o dar a entender, que cuando nos referimos a un Derecho Disciplinario "*autónomo e independiente*" lo hagamos para decir que este no tiene nada que ver con el Derecho Administrativo o con el Derecho Penal. Precisamente, porque sí tiene que ver es que importa el planteamiento sobre las diversas naturalezas referibles en adelante[55], cuando hemos ligado su desarrollo con la metodología dogmática que parte de la distinción y agrupación a partir de lo que resulte semejante o diferente, elevando cada una de dichas distinciones a categorías y subcategorías que van del género a las especies y subespecies.

El Derecho Sancionador es el género y entre las especies se encuentra, como lo ha definido la Corte Constitucional, la especie Derecho Disciplinario con sus respectivas subespecies, pero diferenciado de otras especies como el Derecho Penal y el Derecho Contravencional General o Administrativo Penal, como lo entienden otros autores, que no distinguen de este –puesto que lo involucra– al Derecho Disciplinario, que funge solamente como una de sus subespecies[56], tal cual sucede con los cultores del Derecho Sancionador Administrativo, incapaz de explicar la naturaleza ético-jurídica que lo confirma como especie y no como subespecie, pues no puede tener el mismo sentido el reprochar por culpable a un servidor público que sancionar a un banco porque se desencaja en la proporción que debe guardar en sus arcas de los depósitos de sus cuentahabientes.

Aquí se muestra insuficiente la explicación de la naturaleza administrativa del Derecho Disciplinario, que bien vista es del Derecho Sancionador de tal orden, pues no se puede, si se quiere ser coherente y sólido con una explicación, meter en el mismo costal al Derecho Disciplinario de la función pública y el derecho sancionador del medio ambiente, bursátil, de valores, bancario, etc.[57-58]. Lo diferente debe ser tratado de manera distinta y lo igual

---

55 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo,* cit., pp. 34 y 39.

56 Muy buenos ejemplos de la multifacética expresión del Derecho Administrativo Sancionador en Ospina Garzón, *El fundamento del poder de sanción de la Administración: terapia para el abandono de un complejo*, cit., pp. 35 y ss.

57 Parejo Alfonso, Luciano. "El derecho sancionador, en particular la disciplina urbanística y sus problemas en el derecho español", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. xix Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Alberto Montaña Plata & Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 389 y ss.

58 Ya, en sí, resulta un verdadero problema conceptualizar en qué consiste la "relación especial de sujeción" en ese maremágnum de subespecies del Derecho Sancionador Administrativo: Sanz

así mismo, puesto que la relación especial de sujeción basta para el primero pero no para el segundo, donde, por mucho que se quiera estirar la figura dogmática, esta resulta improcedente y debe entonces echarse mano o de una ampliación inusitada de su órbita de entendimiento o de plantear que diferentes planos del derecho sancionador administrativo se fundan en una relación general de sujeción, que por supuesto no es asunto exclusivo del Derecho Penal. Pero, además, esas manifestaciones del derecho sancionador administrativo, que no se fundan en una "*relación de función pública*", no creemos que puedan llamarse Derecho Disciplinario, al menos como aquel que se sustenta en la existencia de una relación especial de sujeción, ni que requieran abrir un nuevo capítulo sobre una nueva especie, pues el método dogmático aconseja agruparlos en una especie diferente.

Por tanto, no se trata de ruptura con el Derecho Administrativo[59], sino de su debida complementación para darle una respuesta adecuada y apropiada a todas y cualquiera que sea la subespecie o modalidad del Derecho Disciplinario de que se trate. Por supuesto, de acuerdo con Rojas López en cuanto afirma que el *ius puniendi* es uno solo y que a este pertenece el Derecho Disciplinario, así como que el Derecho Penal es la *ultima ratio* de los mecanismos de control social y el derecho administrativo sancionador la "*penúltima*", pero creemos que no se acierta cuando se afirma que el Derecho Disciplinario es "*una faceta del derecho administrativo sancionador*"[60].

Si el Derecho Disciplinario en Colombia se predica de una multiplicidad de sujetos y relaciones jurídicas, incluso independientes de la relación pública estricta de los servidores que ostentan tal naturaleza, como sucede con particulares que ejercen funciones públicas a quienes por extensión pueden considerarse bajo una "*relación especial de sujeción pública ampliada*", muchos otros se encuentran por fuera de esta en su versión meramente administrativa o potestad doméstica, como sucede con funcionarios –desde 1991– y empleados judiciales –a partir de 2015, nuevo artículo 257 de la Carta Política–, el Procurador General de la Nación cuyo juzgamiento

---

Rubiales, Iñigo. "Reflexiones sobre las sanciones en la educación: el régimen disciplinario de los alumnos", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. xix Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Alberto Montaña Plata & Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 430 y ss.

59 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., pp. 68 a 73.

60 Rojas López. *La antijuridicidad material: ¿elemento de la potestad sancionadora de la Administración?*, cit., pp. 190, 192 y 195.

disciplinario tiene naturaleza judicial o los sujetos a procesos de pérdida de investidura o los sujetos al *impeachment* constitucional; o como particulares, tratándose los auxiliares de la justicia –artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2, inciso 3.°, de la Ley 1952 de 2019[61]– o los particulares sujetos al Derecho Disciplinario Empresarial –Código Laboral, Sentencia T-276 de 2014– o al Derecho Disciplinario Organizacional, cuya respuesta no la da ni la podrá dar el Derecho Administrativo, sin contar con una nueva expresión del Derecho Disciplinario que se avecina con lo que podríamos denominar "*Jurisdicción Convencional*"[62-63], a partir de las muy seguras observaciones que realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la reclamación de la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el Caso Petro *vs*. Colombia. *¿Tiene respuesta a ello la Potestad Disciplinaria de la Administración Pública? ¿La tienen los cultores de un Derecho sancionador Administrativo que devore al Derecho Disciplinario? Si lo que reclaman estos, supuestamente por virtud de nuestra propuesta, es que no se diluyan las garantías constitucionales en un Derecho Disciplinario autónomo e independiente, ¿con cuáles herramientas entonces contarán el cúmulo de sujetos y relaciones disciplinarias que no se fundamenten en la relación jurídica-pública que presupone la Potestad Sancionadora de la Administración?*

Muy seguramente también, en su época y momento, en tales dilemas se encontraban los hoy especialistas en Derecho Laboral y Derecho Comercial respecto del Derecho Civil. Ni uno ni otros se han acabado; lo único cierto es que la racionalización del ejercicio del poder estatal se ha mejorado sustancialmente como aplicación lógica del concepto de "*República*", que preside el artículo 1 de la Carta Política; también, para el Derecho Disciplinario,

---

61 *Cfr*. Roa Salguero, David Alfonso. "Régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia: competencia para investigarlos", en *Debates fundamentales sobre Derecho Disciplinario*, Gómez Pavajeau, Carlos Arturo & Pinzón Navarrete, John Harvey (directores). Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 2020.

62 Así lo hemos planteado en el Prólogo al libro de David Alfonso Roa Salguero & Carlos Arturo Duarte Martínez. *Garantías convencionales en el Derecho Disciplinario*. Bogotá, Ediciones Gustavo Ibáñez, 2020.

63 Con toda razón se dice que el control integral demandado por el Consejo de Estado en el juzgamiento de actos administrativos sancionatorios debe por supuesto incluir el *control de convencionalidad*: Marín Hernández, Hugo Alberto. "Algunas cuestiones problemáticas en torno del control judicial de decisiones adoptadas en el ejercicio del *ius puniendi* de la Administración", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. xix Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Alberto Montaña Plata & Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 352 y ss.

ello resulta deseable y aplicable, si partimos de la tesis del "*fundamento en la jerarquía*", que brillantemente expone Ospina Garzón, pero que, por sí solo, no tendría respuesta en la potestad doméstica de imponer sanciones por parte de la Administración a servidores públicos por fuera de la Rama Ejecutiva o particulares en otros ámbitos de poder[64], ante lo cual ya se pueden encontrar respuestas parciales[65].

No estamos confundiendo la naturaleza del Derecho Disciplinario, solo que este es mucho más que el Derecho Disciplinario de la Función Pública –por ejemplo, como la entiende Pedro Alfonso Hernández[66]–; por lo tanto, la naturaleza administrativa es apenas una aproximación, que debe ser complementada para otras de sus manifestaciones con una categoría superior, que no es otra que un concepto de Derecho Contravencional General o Penal Administrativo o Administrativo Penal, o como Derecho Administrativo Sancionador que como especie en España involucra al Derecho Disciplinario como una de sus subespecies. Aquí, precisamente, reside la especificidad y muy especialmente la sustantividad del Derecho Disciplinario colombiano, que es diferente a otras manifestaciones del Derecho Sancionador Administrativo como muy temprano lo puso de presente la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la primera mitad de los años ochenta del siglo pasado.

Por supuesto: una cosa es la potestad y otra la regulación normativa que se hace de una específica modalidad de Derecho Sancionador. Lo cierto es que, cualquiera que sea la manifestación del Derecho Disciplinario, este es uno solo con diferencias específicas en cada uno, lo que no obsta también para que existan diferentes explicaciones sobre el origen y la naturaleza de la potestad, lo que no prejuzga sobre el contenido de las subespecies, pero muy seguramente incidirá en ella.

Así, es posible que la potestad sancionadora tenga origen en la potestad doméstica de la administración para manejar sus asuntos organizativos o de

---

64 *Cfr*. Ospina Garzón. *El fundamento del poder de sanción de la Administración: terapia para el abandono de un complejo*, cit., pp. 38 y ss.

65 *Cfr*. Del Pilar Frías Ávila, Paola. *Poder subordinante del empleador e intimidad del trabajador en Colombia*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020.

66 *Cfr*. Alfonso Hernández, Pedro. "Autonomía e independencia del Derecho Disciplinario: ¿oportunidad para revisar el plan de vuelo?", en *Debates fundamentales sobre Derecho Disciplinario*, Gómez Pavajeau, Carlos Arturo & Pinzón Navarrete, John Harvey (directores). Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 2020.

la empresa particular para poner orden interno en sus oficinas o factorías, pero esto ya es asunto de la debida explicación, fundamentación y sustentación de sus subespecies, pero que encuentran un ligamen común a partir de la especie, que en el caso del derecho disciplinario parte de una noción de ilícito fundado en componentes ético-jurídicos[67] y en una culpabilidad normativa. Piénsese, por ejemplo, en el Derecho Disciplinario Deportivo en materia de dopaje en las competiciones, donde se conjugan reglas de organismos internacionales privados con su elevación a instrumentos normativos internacionales, que se incorporan como normas jurídicas a nivel nacional, todo lo cual escapa, por supuesto, a una explicación viable a partir de la potestad doméstica de la Administración[68].

Lo anterior, por supuesto, es totalmente diferente en otros sectores del Derecho Sancionador Administrativo que no tienen tal significancia, pues en estos podría incluso prescindirse de la culpabilidad como reproche, solo formulable frente a personas naturales como lo son las del Derecho Disciplinario, atributo ausente en el Derecho Sancionador Administrativo como Derecho Contravencional General, pues aquí se trata de una especie

---

67 Así lo acepta, citando la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., p. 61. Ese contenido ético-jurídico del ilícito disciplinario no aparece en el contenido y sentido de lo contrario a derecho del Derecho Contravencional General o Penal Administrativo, donde el ilícito tiene una connotación neutral, pues lo que se busca con las prohibiciones y mandatos que generan sanciones administrativas es "desestimular su violación" toda vez que "en tanto su valor reduce el riesgo de que el incumplimiento resulte mejor que su acatamiento" por parte de servidores públicos o particulares "destinatarios" de las normas, al "conferir mayor vigor a las tareas de vigilancia y control del sector", se lee en la Sentencia C-016 de 2016. No hay duda, allí los fines de derechos sancionatorios que no tienen como contenido de ilicitud el desvalor de acción de una conducta de contenido ético.

68 "Es importante destacar que para 2005 la Conferencia General de la Unesco aprobó la Convención, estableciendo un instrumento jurídico que es obligatorio y con alcance universal. Este instrumento fue la forma en que la lucha internacional contra el dopaje pudo justificar la eficacia jurídica de normas de carácter privado como el CMA, dentro del ordenamiento jurídico de un país. Lo anterior debido a que las normas de este son normas provenientes de una fundación de carácter privado (AMA), y para la aplicación de dichas normas dentro de los Estados, estos se han comprometido por medio de la ratificación de la Convención Unesco de 2005 en sus legislaciones internas.
La ratificación de la Convención Unesco, significa para los Estados la aceptación de los principios del CMA, esbozado en el articulado de la misma, en el que se señala el compromiso de estos en el respeto de los principios antidopaje del mismo, exigiéndoles adoptar medidas acorde con estos principios, pero igualmente permitiéndoles ratificar estas normas antidopaje conforme existen sus competencias constitucionales": Martínez Acuña, Luisa Fernanda. *El procedimiento sancionatorio de dopaje en Colombia y su afectación a los derechos fundamentales del deportista*, tesis de grado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020, p. 20.

del Derecho Sancionador diferente en cuanto el elemento común es la naturaleza administrativa del acto y su control judicial por el Contencioso Administrativo.

La especie del Derecho Disciplinario implica la existencia de un acto administrativo y su control por la misma jurisdicción cuando se trata del Derecho Disciplinario de la Función Pública[69], atributos no presentes sin más ni más en otras subespecies del Derecho Disciplinario como el que se aplica a funcionarios y empleados judiciales como abogados en el ejercicio profesional, cuyos actos son actos jurisdiccionales no controlables por el Contencioso Administrativo, o de profesionales de otras disciplinas por virtud de la potestad sancionatoria en cabeza de los colegios profesionales (artículo 26 de la Carta Política) o de los particulares trabajadores de las empresas particulares como actos del Derecho Laboral controlables por la Justicia Laboral o por miembros de organizaciones particulares como clubes sociales, clubes deportivos, sindicatos, colegios, universidades, etc., cuyo único control posible es el mecanismo de la acción de tutela.

El contenido del Derecho Disciplinario, por supuesto, difiere del referido a derechos sancionadores administrativos sin contenido ético-jurídico o, lo que es lo mismo, regidos por la relación general de sujeción[70], para lo cual basta observar, por ejemplo, lo que dice la Sentencia C-016 de 2016:

> Para la Corte, establecer un *régimen sancionatorio* cuyo objeto consista en alcanzar los propósitos indicados, contribuye efectivamente a promover el sector de las TIC y, en esa medida, apoya, favorece u optimiza la consecución de los propósitos del Plan General de Desarrollo. Esto muestra que existe entre la norma instrumental analizada y los objetivos generales del Plan una conexidad directa e inmediata.
>
> La conclusión anterior encuentra apoyo en diferentes razones.
> a) *Prever sanciones por la comisión de faltas de naturaleza administrativa busca asegurar la vigencia de aquellas normas que consagran deberes a cargo de los particulares o de los funcionarios públicos. También pretende, cuando los destinatarios de las normas no las cumplen por razones morales, establecer incentivos de cumplimiento o, de otra*

---

69 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., pp. 44 y 45.

70 Esta distinción pareciera que fue consciente en la Asamblea Nacional Constituyente, como se puede apreciar en la sesión del 15 de abril de 1991 de la Comisión Cuarta, donde se concibe por un lado con visos claros de independencia al Derecho Disciplinario –*responsabilidad disciplinaria*– y por otro al de las "contravenciones administrativas", poniéndose como ejemplos de estas a la policía económica, comisión de valores, etc.

forma dicho, disuadir a sus destinatarios para abstenerse de actuar de manera contraria al ordenamiento. La existencia de sanciones administrativas se orienta también, de manera específica, a reprochar los comportamientos particulares opuestos al ordenamiento jurídico, así como a neutralizarlos para que en el futuro los obligados se abstengan de incurrir en ellos. En ese sentido, la Corte ha dicho que "la potestad sancionadora de la Administración permite asegurar la realización de los fines del Estado, al otorgarle a las autoridades administrativas la facultad de imponer una sanción o castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que exigen un determinado comportamiento a los particulares o a los servidores públicos, a fin de preservar el mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la organización estatal (C. P. arts. 1°, 2°, 4° y 16)"[71].

Revisada desde esta perspectiva la disposición que se acusa, la Corte encuentra que *la fijación de sanciones por el incumplimiento de los deberes a cargo de las personas que participan en las industrias* que componen el sector de las TIC –en tanto contribuye a la vigencia y respeto de las normas que rigen tal sector– es una condición de efectividad de las estrategias previstas en el Plan –*Competitividad e infraestructura estratégicas*– y, por tanto, un instrumento para materializar los pilares del Plan Nacional de Desarrollo –en especial la "*Paz*" y la "*Equidad*"–.

b) La conexidad del artículo cuestionado con los objetivos generales del Plan es pues directa y no hipotética o conjetural. *En efecto, la disposición que establece las sanciones por la comisión de las infracciones administrativas previstas en el artículo 64 de Ley 1341 de 2009 persigue, a través de la enunciación precisa de las consecuencias negativas de tal infracción, evitar comportamientos que afecten el avance de la cobertura y calidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones*. Los deberes que subyacen al grupo de infracciones sancionadas, tienen como norte la garantía de idoneidad de los agentes del sector, la calidad de los servicios que prestan, la protección de los usuarios, el amparo de derechos constitucionales de significativa relevancia y la creación de condiciones para que las actividades de vigilancia a cargo del Estado se desarrollen correctamente. (Resaltado fuera de texto).

La Corte Constitucional ha precisado, de acuerdo con lo anterior, que se requiere, con "énfasis en la necesidad de dotar a la administración pública de instrumentos idóneos para el cumplimiento de las tareas que le competen", habida cuenta de que según la Sentencia C-914 de 2001:

---

71 C-818 de 2005.

> La legitimidad del Estado Social de Derecho radica, por un lado en el acceso y ejecución del poder en forma democrática, y por otro lado en su capacidad para resolver las dificultades sociales desde la perspectiva de la justicia social y el derecho, lo cual indudablemente depende de la capacidad del Estado para cumplir, de manera efectiva, con sus fines de servicio a la sociedad. De ahí pues, que los mandatos contenidos en los artículos 2.° y 209 de la Constitución imponen a las autoridades la obligación de atender las necesidades, hacer efectivos los derechos de los administrados y asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales.
>
> Ahora bien, la efectividad de los derechos se desarrolla con base en dos cualidades, la eficacia y la eficiencia administrativa. La primera relativa al cumplimiento de las determinaciones de la administración y la segunda relacionada con la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos. Es por ello que las dos cualidades permiten la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones.
>
> 6. En este orden de ideas, el logro de los objetivos y fines del Estado requieren de una función administrativa eficiente que responda a las exigencias del Estado Social de Derecho [...][72].

La Sentencia C-914 de 2001 es muy clara en señalar respecto al significativo papel que juega la ética en el Derecho Disciplinario:

> La Corte Constitucional encuentra deseable y, más aun, imperativo, a la luz de los retos y responsabilidades que impone el Estado Social de Derecho, que se prevean mecanismos institucionales aptos para alcanzar la modernización y eficiencia de los entes públicos, capacitando a sus trabajadores, estructurando adecuadamente el conjunto de funciones que les corresponde cumplir, reduciendo las plantas de personal a dimensiones razonables y separando de sus cargos a los empleados cuya ineptitud o *inmoralidad sean debidamente comprobadas*.
>
> Pero, claro está, ello únicamente puede hacerse partiendo de la plena observancia de los principios y disposiciones constitucionales, en especial de aquellos que

---

72 Sentencia T-068 de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero.

> reconocen los derechos fundamentales de la persona y los que corresponden de manera específica a los trabajadores[73]. (El resaltado es nuestro).

Son los retos inherentes al principio del Estado Social, que, según la Sentencia SU-747 de 1998, implica que

> el Estado de derecho liberal y el Estado social de derecho se diferencian en la relación que construyen entre el Estado y los asociados: así, mientras que el primero busca ante todo limitar el poder, de tal manera que no pueda amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos, el segundo acoge esa limitación del poder, pero también precisa que el Estado debe cumplir con unos fines en la sociedad, lo cual implica que intervenga en ella. La Constitución dentro de este último modelo de Estado representa un cuerpo armónico de valores –acerca de cómo debe configurarse la comunidad social y política–, que debe encontrar su aplicación práctica, y ello produce tanto deberes para el Estado como para los asociados".

Por supuesto, debe apreciarse del Derecho Disciplinario, diferente a lo que sucede con otras manifestaciones del Derecho Sancionador Administrativo, que su inmanente contenido ético viene demandado de una ética de lo público (artículos 88, 92 y 209 de la Carta Política), lo que lleva inexorablemente al cumplimiento del principio de culpabilidad, pues, según Sentencia T-677 de 2004, "el debido proceso implica la proscripción de la responsabilidad objetiva, toda vez que aquella es 'incompatible con el principio de la dignidad humana' y con el principio de culpabilidad acogido por la Carta en su artículo 29".

Por supuesto, si de lo que se trata es de partir de la potestad que tiene una determinada autoridad para deducir de allí la pertenencia del Derecho Disciplinario al Derecho Sancionador Administrativo[74], es asunto que se apoya en lo más primitivo del criterio orgánico, *pues nos preguntamos: ¿qué de común, distinto a lo anotado, tiene el Derecho Disciplinario de la Función Pública con el Derecho Administrativo Sancionador en general como para que se justifique su misma naturaleza?*[75].

---

73 Sentencia C-479/92, MM. PP. Alejandro Martínez Caballero y José Gregorio Hernández Galindo.

74 *Cfr*. Rincón Córdoba. *Origen, justificación y presupuestos de la potestad sancionadora de la Administración en el ordenamiento jurídico colombiano*, cit., pp. 83 y ss.

75 Muy sugerente y rico, Carvajal Sánchez, Bernardo. "Claroscuro de los regímenes de responsabilidad en el derecho administrativo sancionatorio colombiano", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. XIX Jornadas Internacionales de Derecho

Ahora, cuando la Corte Constitucional en sentencias que van de la C-417 de 1993 a la T-276 de 2014 dice que el Derecho Disciplinario es uno solo, allí lo que se esgrime es un concepto sustancial para definir su naturaleza, que es en lo cual nos apoyamos para la propuesta de autonomía e independencia y no vemos aporía alguna allí, sino un punto de vista que nos parece más convincente que el orgánico exclusivo y excluyente de los administrativistas.

Por supuesto que es indiscutible la solidez del argumento de Rincón Ospina para la explicación del amplio y extenso ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, el cual se caracteriza por un *in crescendo* por el advenimiento del Estado Intervencionista, con lo cual estamos plenamente de acuerdo por la evolución sufrida por el Derecho Administrativo e incluso por la noción de "*relación especial de sujeción*" por el principio social del Estado, pero de allí a que *per se* de dicho argumento se derive la naturaleza administrativa del Derecho Disciplinario en la actualidad, como lo pretende Rojas López, no deja de ser mucho más pretensioso que la adscripción de autonomía e independencia: *de la falacia naturalista a la falacia organicista*.

Ya el asunto no es de una excepción, la de los funcionarios judiciales, sino de muchas excepciones donde estas toman el concepto de generalidad y la doctrina hace agua y una nave nueva debe portar su objeto, sin que ello implique abandonar a la categoría dogmática superior del Derecho Disciplinario como lo es la "*relación especial de sujeción*"[76].

Tampoco significa que las reflexiones sobre Derecho Disciplinario tengan que ser ajenas al Derecho Administrativo[77]. Nunca podríamos afirmar un tal concepto y jamás se nos podría enrostrar una tal afirmación. Desde muy temprano, fuimos claros en señalar que "*la relación especial de sujeción es, al Derecho Disciplinario de la función pública, lo que la teoría del bien jurídico es para el Derecho Penal*", pues aquella se revela como "*categoría dogmática superior del Derecho Disciplinario*"[78]. Creemos y queremos ser claros: ni excluimos al Derecho Penal ni excluimos al Derecho Administrativo de la Función Pública, pero, por supuesto, el Derecho Disciplinario es mucho más que esto, si se quiere que se explique su multiformidad o multidimensionalidad de

---

Administrativo, Alberto Montaña Plata & Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 223 y ss.

76 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., p. 47.

77 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., p. 41.

78 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *La relación especial de sujeción como categoría dogmática superior del Derecho Disciplinario*. Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 2003.

expresiones, que ya hoy no se circunscribe ni siquiera a lo nacional, sino que también demanda una comprensión de sus manifestaciones internacionales, como sucede, por ejemplo, en la discusión sobre el contenido y los alcances del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por ello, desde hace mucho tiempo, venimos hablando acerca del correcto entendimiento del concepto de autonomía e independencia, el cual debe predicarse en términos relativos desde una perspectiva estructural del Derecho y ahora sí absoluta desde el punto de vista funcional, lo que demanda la imposibilidad de desconocer la importancia recíproca entre las diferentes ramas del Derecho[79]. Ahora, no practicamos la idea de que por afirmar la autonomía e independencia del Derecho Disciplinario surja su identidad; por el contrario, dada su identidad en Colombia por virtud de su regulación constitucional y por ser calificado como uno solo por la jurisprudencia, es por lo cual calificamos su autonomía e independencia.

Por supuesto, la relación especial de sujeción y el Derecho Administrativo explican muy bien el Derecho Disciplinario de la Función Pública, a saber, el de los servidores públicos –especialmente el de los pertenecientes a la Rama Ejecutiva– y hasta el de los particulares que ejercen funciones públicas, pero no muy bien el de otros servidores públicos no sometidos a las jerarquías administrativas –gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, etc.– o por fuera de la Rama Ejecutiva –congresistas, funcionarios judiciales–, profesionales liberales o particulares en las empresas y las organizaciones de tal naturaleza, amén de otros sectores como el deportivo con clara vinculación y dependencia de estructuras internacionales privadas o no del todo públicas.

No por ello despreciamos la relación especial de sujeción o decimos a la ligera que ella no se observa por ningún lado. Al respecto, seguimos pensando en que ella es una categoría dogmática superior; empero, habrá que encontrar un equivalente para el fundamento de, por ejemplo, el derecho disciplinario fundado en el Derecho Laboral a que se refiere muy particularmente la Sentencia T-276 de 2014. Mal haríamos en estos sectores del Derecho Disciplinario, donde no existe una explicación a partir de la potestad

---

79 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. "El Derecho Disciplinario como disciplina jurídica autónoma", en *Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública*, año xxxiv, n.° 403. Buenos Aires, Ediciones rap, 2012.

doméstica propia del Derecho Administrativo, que demandan por supuesto una "*reflexión ajena al Derecho Administrativo*"[80].

Son múltiples las facetas del Derecho Disciplinario que van de lo público a lo mixto y a lo privado; sin importar su naturaleza, el Derecho Disciplinario es uno solo, como contundentemente se dice desde la Sentencia C-417 de 1993 a la T-276 de 2014. Allí la particularidad del Derecho Disciplinario colombiano que ahora, para no herir susceptibilidades, preferimos llamar Derecho Disciplinario Constitucional, de próxima aparición[81-82].

Sin duda alguna, las afirmaciones de los cultores de la naturaleza administrativa del Derecho Disciplinario son contribuciones invaluables a nuestra disciplina; se constituyen en motores de impulso para el avance de los estudios de la ciencia, pero no es menos cierto que en ese diálogo, sabiamente planteado por Rincón Córdoba[83], faltan otros elementos que resultan consustanciales a las particularidades del Derecho Disciplinario colombiano.

Múltiples posiciones explican, desde ópticas muy diferentes, la naturaleza del Derecho Disciplinario. Todas, sin excepción, guardan su verdad y en su conjunto sugieren una visión panteísta que tiene que conducir a una propuesta de amplios horizontes. Ahora, no discutamos sobre lo nominal; vayamos a las esencias; no nos desgastemos en una discusión de no terminar y mejor hablemos de Derecho Disciplinario Constitucional.

El Derecho Disciplinario, por ser indefectiblemente necesario, debe hacerse práctico. Así lo impone el "*control*" que resulta inmanente a todo y cualquiera sea la modalidad de Estado y organización puesta de presente por la historia[84], como se reconoció por el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta Padilla, cuando presentó el proyecto de ley que se convertiría más tarde en la Ley 200 de 1995.

La idea de un Código Disciplinario Único operó como el *bosón de Higgs* para atraer toda manifestación de la potestad disciplinaria, por supuesto la administrativa, encabezada por la responsabilidad de los servidores públicos,

---

80 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., pp. 40 y 41.

81 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo & Roa Salguero, David Alfonso. *Derecho Disciplinario Constitucional*. Sin publicar.

82 También Gómez Pavajeau. "Aspectos decisivos que determinaron, determinan y determinarán la evolución del Derecho Disciplinario en Colombia", cit., pp. 193 y ss.

83 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., pp. 33 y ss.

84 *Gaceta del Congreso*, Senado y Cámara, año II, n.° 31, del 9 de marzo de 1993. Bogotá, Imprenta Nacional, p. 10.

pero también la de otros servidores públicos diferentes a los pertenecientes a la Rama Ejecutiva y hasta a los particulares que ejercen funciones públicas. Se demuestra, con ello, que el Derecho Disciplinario es mucho más que la potestad doméstica, y si se acude a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre lo que es un régimen disciplinario, el criterio orgánico es apenas uno de los muchos insumos que se tienen en cuenta.

Tal criterio orgánico, por supuesto[85], pierde gran fuerza si se tiene en cuenta que el artículo 2 del CPACA excluye en principio de sus disposiciones al Código Único Disciplinario o al Código General Disciplinario, salvo en materias que impliquen solventar vacíos legislativos. Así también, ahora de manera expresa no solo para asuntos procedimentales, sino también sustanciales, su artículo 47. Pero además, si se utiliza otro criterio orgánico, no guardan similitudes los procesos de pérdida de investidura con el control contencioso administrativo y, por supuesto, otras expresiones de la voluntad estatal, como los fallos disciplinarios contra el Procurador General de la Nación, magistrados de altas cortes, Fiscal General de la Nación y Presidente de la República, no tienen tal tipo de control.

¿Son las "*actuaciones administrativas contractuales sancionatorias*" también Derecho Administrativo, por tanto Derecho Sancionador Administrativo, sin más ni más? *¿O pertenecen a otra especie del Derecho Sancionador que conocemos como Derecho Correccional o, como prefiero llamarlo, Derecho de Orden Procesal Interno*? *¿Cuál la razón para que no se les aplique el Procedimiento Administrativo Sancionador del CPACA, según el parágrafo de su artículo 47*? *¿Existe en esta expresión del derecho sancionador que sugiere, como se sugiere respecto del Derecho Disciplinario, que son especies diferentes del Derecho Contravencional General o Derecho Penal Administrativo*? Algún significado debe tener la palabra de la ley como símbolo comunicativo o ¿se trataría de meras anomalías o entuertos legales sin significación alguna?

---

85 Muy significativo que se diga que, más allá de un criterio orgánico exangüe, resulta relevante "precisar la naturaleza de la disciplina es un asunto trascendente para evaluar las dimensiones de la autonomía y la interpretación y aplicación de sus categorías, principios y normas jurídicas": HERNÁNDEZ, PEDRO ALFONSO. "Naturaleza del Derecho Disciplinario: ¿función administrativa o administración de justicia?", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, ALBERTO MONTAÑA PLATA & JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 655 y ss.

Cuando el contencioso administrativo hace uso, para efecto de modular la sanción, del artículo 187 inciso 3.° del CPACA, clara expresión material y sustancial de juzgamiento, ¿muta la naturaleza administrativa del Derecho Disciplinario o su propia y autónoma naturaleza le prestan legitimidad para tal manifestación?[86] Nuevamente organicidad *vs*. materialidad, un fundamento original en la potestad doméstica de la administración o en algo más.

Pero, además, un asunto escapa también del control contencioso administrativo, que se revela como un problema de grandes y serias dimensiones: *¿Puede el juez laboral negar el levantamiento de la protección por fuero sindical de un servidor público o un particular que ejerce funciones públicas que ha sido declarado responsable disciplinariamente y consecuentemente sancionado? ¿Interfiere el juez laboral en el ejercicio de la potestad doméstica? ¿Quiebra ello el poder inherente a la potestad doméstica?*

Muestra ello, en consecuencia, que no resulta un despropósito buscar unos elementos propios del Derecho Disciplinario que lo diferencien de otras manifestaciones del Derecho Sancionador Administrativo, y a partir de allí proponer su propia sustancialidad, pues lo que se esgrime como pivote central para su pertenencia al Derecho Administrativo es un criterio orgánico que no se practica en sus versiones sobre jurisdicción y competencia para conocer de funcionarios y empleados judiciales, particulares auxiliares de la justicia, particulares que administran justicia, Procurador General de la Nación, congresistas y pérdida de investidura en general, magistrados de las altas cortes, Fiscal General de la Nación y Presidente de la República, a más de ellos, si entendemos la moción de censura como una expresión del Derecho Disciplinario.

Que no se diga que nuestra propuesta de un Derecho Disciplinario autónomo e independiente rebaja y hasta menosprecia las garantías constitucionales cuando, precisamente, partimos del fenómeno indesconocible de la constitucionalización del derecho y conscientes del precepto rector del

---

86 Con toda razón se dice que "la labor de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como segunda fase de la actuación disciplinaria que se desarrolla dentro del Sistema de Responsabilidad Disciplinaria no está regida por el modelo de justicia rogada en la que el funcionario judicial solo estudia aquellos cargos propuestos por el demandante": GÓMEZ LEE, IVÁN DARÍO & URREGO ORTIZ, FRANKY. "Sistema de Responsabilidad Disciplinaria en Colombia", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, ALBERTO MONTAÑA PLATA & JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, p. 760.

artículo 29 de la Carta Política, según el cual "*el debido proceso se aplicará a toda clase de actuación, judicial o administrativa*".

Pero, además, uno de nosotros, como Viceprocurador General de la Nación, propuso una fórmula del debido proceso donde su faceta sustancial o material quedará explicitada de manera clara e incontrovertible, que quedó como tal plasmada en el artículo 6 de la Ley 734 de 2002, según la cual "*el sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público*", redacción que se conserva en el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 y que respaldamos también, como tal, del artículo 12 de la Ley 1123 de 2007, tal como lo refrendamos con nuestro trabajo sobre el proceso disciplinario oral elevado a módulo de estudio por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, del cual uno de los autores ha sido consultor y formador en el entrenamiento de quienes deben guiar los cursos-concursos[87].

El otro, como veedor de la Procuraduría General de la Nación y ahora como magistrado auxiliar de la Sección Segunda del Consejo de Estado, puede dar cuenta de que el derecho administrativo se torna insuficiente para explicar las particularidades y especificidades que rigen esta especial materia. Sin duda, esta es imposible agotarla desde las solas huestes del sector de quienes reclaman fustigadamente su naturaleza, soslayándose la transversalidad y la multididimensionalidad de los tópicos que deben resolverse. Ahora, resulta demasiado curioso que uno de los argumentos que se exponen para pregonar la naturaleza administrativa sea el de que el derecho disciplinario bebe de las categorías penales, porque, entre otras cosas, muchas de las conductas están asociadas con algunos delitos. Por ello, no exageramos que en algunas ocasiones opera aquella máxima de que se pretenden ganar "indulgencias con avemarías ajenas".

En nuestros escritos, y retomando el tema de las garantías, no dejamos de insistir en la necesidad de aplicar el Bloque de Constitucionalidad y sus garantías al Derecho Disciplinario, reclamando muy vigorosamente la

---

87 Énfasis en el concepto de "debido proceso sustancial": Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *La oralidad en el proceso disciplinario de los abogados.* Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2015, en Unidad 1, aparte 1.3, sobre "La oralidad, debido proceso, derecho de defensa y la contradicción".

aplicación del *principio pro homine o pro libertate*, según los cánones hermenéuticos precisados en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para terminar, solo queremos precisar que quienes descalifican nuestros argumentos señalando incorrecciones metodológicas, no se dan cuenta que son ellos, al apegarse a la doctrina europea en cabeza de alemanes, franceses y españoles, quienes están desconociendo nuestras propias realidades, pues la afirmación acerca de que ya se superó la discusión sobre las diferencias entre injusto penal e ilícito administrativo solo puede ser entendida a partir de una hipervalorización del desvalor de acción o de la antijuridicidad formal, obra de las tendencias alemanas y españolas sobre subjetivización del injusto, donde la diferencia no es de tipo cualitativo sino cuantitativo o, mejor, de grado, lo cual es compatible con sus fórmulas sobre el libre desarrollo de la personalidad –complejas alternativas– y no con la nuestra de que da cuenta el artículo 16 constitucional, de claro raigambre liberal, de naturaleza compleja acumulativa, donde no juega papel alguno la moral, y los derechos de los demás y el orden jurídico operan sin posibilidad de escisión como allá tiene ocurrencia.

Hay que tener mucho cuidado de transportar sin el debido análisis lo afirmado en otras latitudes, donde se aspira a que tales doctrinas se acojan en nuestro medio jurídico sin tener en cuenta sus peculiaridades, encontrándonos con la paradoja que la doctrina extranjera entra a Colombia como "Pedro por su casa", según dicho popular, y no así los tratados internacionales sobre derechos humanos que deben ser sometidos a un previo juicio de ponderación de estándares, según se desprende de los artículos 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 93 de la Carta Política, donde el Orden Público Internacional de los Derechos Humanos cumple el doble rol de servir de fuente del derecho de aplicación inmediata y criterio hermenéutico para la debida comprensión de los derechos y deberes constitucionales, y no al contrario, como a veces se puede percibir. *¿Por qué razón no se enjuicia, con el mismo rigor con que se analiza previamente la aplicación de una norma internacional sobre derechos humanos, la doctrina extranjera*? Por supuesto, no somos chovinistas, pero tampoco creemos que resulta adecuado seguir a rajatabla la doctrina extranjera, muy especialmente cuando se identifican en ella diferencias sustanciales con nuestro ordenamiento constitucional, como muy bien se destaca nuestro concepto de injusto penal orientado sobre la base del desvalor del resultado, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en

Alemania y España, donde el mismo se encuentra orientado por el desvalor de acción, precisamente lo que hace que entre delito y falta administrativa no existan diferencias cualitativas sino cuantitativas, pues predomina más allá del Atlántico un concepto de antijuridicidad formal[88].

Como gran logro esgrimen la aplicación del principio de culpabilidad de estirpe penal al Derecho Sancionador Administrativo, sin percatarse de que la presunción de inocencia en Alemania y España desde donde importan "*sin licencia previa y sin control valorativo*" sus argumentos, opera de manera muy diferente de como lo hace en Colombia, pues más allá del Atlántico solo se presume en favor del reo la no autoría, la participación y la adecuación típica, pero cualquier excluyente de responsabilidad, incluidas las de antijuridicidad y culpabilidad, se encuentra a cargo de la defensa. Pues bien, si la presunción de inocencia se encuentra matizada en Derecho Sancionador Administrativo con respecto a la garantía penal, obviamente lo aprovechable es mínimo, todavía más reducido para el sancionador administrativo. La fórmula colombiana tiene niveles de garantía mucho más elevados, opera por supuesto para la autoría, participación y la tipicidad, pero también para las eximentes de responsabilidad incluidas las causales de justificación y de inculpabilidad según la fórmula de presunción de inocencia como presunción de no culpabilidad, de conformidad con el artículo 29 constitucional colombiano, que por hacer parte del debido proceso no tiene que salir a mendigar –como ocurre con la doctrina europea– al Derecho Penal, pues se predica tanto de actuaciones judiciales como administrativas. El principio de culpabilidad en Colombia, tanto para el Derecho Penal como para el Derecho Disciplinario, emana y se sustenta en el principio de la dignidad humana, como principio fundante del orden jurídico estatal[89].

Asistimos a lo que podríamos denominar "*el renacer de la naturaleza administrativa del derecho disciplinario*", movimiento impulsado por nuestros colegas del Departamento de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

---

88 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. "Interpretación y aplicación de normas internacionales sobre Derechos Humanos en materias penal y disciplinaria", en *Revista Derecho Penal y Criminología*, volumen xxxiv, n.° 96, enero-junio de 2013. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 187-218.

89 Ver el "Estudio introductorio" de Gómez Pavajeau, Carlos Arturo en *La prueba jurídica de la culpabilidad en el nuevo sistema penal*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.

Los administrativistas trabajan arduamente en la recuperación de la importancia del "poder disciplinario" como parte de la naturaleza administrativa del Derecho Disciplinario, lo cual hace vaticinar que la calidad del discurso jurídico en la materia va a aumentar cuantitativa y cualitativamente.

Seguimos apostando por un Derecho Disciplinario autónomo e independiente, capaz de explicar todas sus manifestaciones, por lo que en este trabajo seguimos aquellos derroteros que muestran cómo en Colombia una visión meramente administrativista resultaría recortada o le dificultaría explicar adecuada y apropiadamente su inserción en un mundo cada vez más globalizado:

Primero: el carácter de *norma de normas* que tiene nuestra Carta Política, que consagra una jurisdicción disciplinaria –comisiones nacional y seccionales de Disciplina Judicial– y otra jurisdicción administrativa que se ocupa de la pérdida de investidura de servidores públicos de elección popular –Consejo de Estado y tribunales administrativos, artículo 237 numeral 5.° de la Carta Política–, regida la primera por la Ley 734 de 2002 –pronto, de sucederse por el Código General Disciplinario–, Ley 1881 de 2018, además de otro componente político como resulta ser el *impeachment* –juzgamiento político disciplinario del Presidente, Fiscal General y magistrados de las altas cortes, artículos 174, 175, 178 numerales 3.° y 4.° y 178A de la Carta Política–, la moción de censura –artículos 135 numeral 9.°, 300 numeral 14, 313 numeral 12 de la Carta Política[90] y 6 numeral 3.°, 18 numeral 7.°, 51 numeral 8.°, 119 numeral 11, 250, 252, 261 y 310 parágrafo de la Ley 5 de 1992– y por supuesto el juzgamiento de los congresistas por la Célula de Ética del mimo cuerpo legislativo –¿actividad de naturaleza administrativa, judicial o legislativa?– de conformidad con la Ley 1828 de 2018, hacen casi que imposible hablar de una disciplina solo sustentada en criterios y fundamentos

90 "La expresión 'demás autoridades', hace referencia a los funcionarios enumerados en las normas constitucionales citadas, todos ellos pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público. Por consiguiente quedan excluidos de la posibilidad de ser citados a las Cámaras o a sus comisiones las autoridades judiciales, por cuanto la Constitución es clara al señalar que el control político que ejerce el Congreso es 'sobre el gobierno y la administración'. Por otra parte, la misma Constitución establece el principio de separación entre las ramas del poder público y prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras autoridades; pero, sobre todo, es perentoria al determinar que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes. La expresión contenida en el numeral 3.° del artículo 6.° acusado debe interpretarse como una manifestación del control político dentro de un sistema de gobierno presidencial": Corte Constitucional, Sentencia C-198 de 1994, M. P. Naranjo Mesa.

administrativos, muy especialmente cuando se ha reconocido que, aun en el derecho administrativo disciplinario, es considerada dicha actividad como Administración de Justicia en sentido material –sentencias C-014 de 2004, SU-901 de 2005 y T-350 de 2011 de la Corte Constitucional–;

Segundo: el reconocimiento de la existencia de un "*único*" Derecho Disciplinario por la jurisprudencia constitucional –sentencias, entre otras, C-417 de 1993 y T-276 de 2014–, muy apto, eficiente y eficaz para explicar aquellas versiones públicas, privadas y delegadas –colegios profesionales del artículo 26 de la Carta Política– del mismo, se erigen en obstáculos casi imposibles de abordar solamente por el Derecho Administrativo con fundamento en la potestad doméstica;

Tercero: los trabajadores oficiales, vinculados por contrato de trabajo, se encuentran en la encrucijada de la aplicación en materia disciplinaria de la Ley 734 de 2002 y el Código Laboral del Trabajo, como además las convenciones colectivas del trabajo, algo que se le escapa de explicar a la potestad doméstica;

Cuarto: los empleados públicos y los trabajadores oficiales sancionados cuando gocen de fuero sindical, para poder ejecutar la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo o destitución, requieren el levantamiento del fuero sindical por parte del juez laboral, el cual puede bloquear la ejecución del fallo (artículos 405 y 406 del Código Laboral), poniendo en cuestionamiento la presunción de legalidad del acto administrativo y la facultad de control del contencioso administrativo, problemática imposible de solucionar de la mano de la teoría de la potestad doméstica de la Administración[91];

Quinto: el juez de lo contencioso administrativo puede, por virtud del inciso 3.° del artículo 187 del CPACA, modular la sanción de la autoridad disciplinaria competente, lo que implica formal y materialmente un acto de juzgamiento disciplinario, lo que controvierte que las facultades disciplinarias se cifren exclusivamente en el poder doméstico de la Administración, puesto que, desde luego, el órgano de lo contencioso administrativo está por fuera del mismo;

---

91 Para el efecto ver decisión de abril 4 de 2019 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, sentencia de tutela de primera instancia de mayo 29 de 2019, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, radicación 55.614, y sentencia de segunda instancia de la Sala de Casación Penal de agosto 13 de 2019, radicación 105.884.

Sexto: la existencia de instituciones disciplinarias en los organismos multilaterales, tratados internacionales, disposiciones vinculantes a los Estados Nacionales por virtud de Tratados de Lucha contra la corrupción y estandarización de buenas prácticas internacionales como el tratado OCDE, resultan propicios para una globalización del Derecho Sancionatorio, refractario a una exclusiva y específica visión "*doméstica*", como subyace al planteamiento administrativista;

Séptimo: igualmente, los conceptos antijuridicidad y juridicidad son propios de la Teoría General de Derecho, de la cual podemos extractar sus dos caras existenciales –antijuridicidad formal y sustancial–, que se expresan en sendas caras de cada una de las especies del Derecho Sancionador –por ejemplo, antijuridicidad formal y material en penal e ilicitud sustancial y formal en disciplinario–, lo que permite, sin excusa u obstáculo alguno, la comprensión de un Derecho Sancionador general y sus expresiones específicas como lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional. Pero además, la existencia de una culpabilidad de naturaleza normativa pregonada para el Derecho Disciplinario completa un cuadro sintomático del cual, necesariamente, se infiere un ADN común a sus subespecies, que lo hacen diferente tanto al Derecho Penal como al Derecho Administrativo Sancionador, sin duda transversal a muchas disciplinas, entre otras, al Derecho Administrativo, lo que muestra con este semejanzas pero también diferencias.

Podríamos agrupar, en busca de la especie, a partir de *i)* la fuente de la cual emana la potestad sancionadora; *ii)* los sujetos pasivos de la potestad sancionadora; *iii)* los controles propios del Estado de Derecho en torno a la decisión de la potestad sancionadora; *iv)* la naturaleza jurídica del procedimiento utilizado; y *v)* la naturaleza ético-jurídica del ilícito –objeto del reproche– y la culpabilidad normativa –sujeto del reproche– de la respectiva manifestación del Derecho Sancionador que se exprese como especie.

Creemos que *i)*, *iii)* y *iv)* son aspectos instrumentales. El primero da cuenta de dónde emana el poder de sancionar, que en principio lo es del Estado; sin embargo, en un Estado Constitucional de Derecho ello no es exclusiva y excluyentemente lo que define el control del poder, puesto que los efectos horizontales de los Derechos Humanos (artículos 2, 3 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y XXX de la Convención Americana de Derechos Humanos) hoy reconocen que lo importante no es a quién debe controlarse –aspectos formales–, sino por qué debe controlarse –aspectos materiales–; el segundo da cuenta del debido proceso, mismo que

procede contra toda decisión judicial o administrativa, de contera ampliados de lo público a lo privado (artículo 29 de la Carta Política); y tercero, la forma que asume el procedimiento sancionador hoy en un segundo plano, pues lo que se controla –qué se controla– es lo que importa al debido proceso y el *cómo se controla* es asunto de forma para la mejor garantía del cumplimiento del Estado de Derecho. En fin, estos aspectos dan cuenta de mecanismos instrumentales que se definen por lo sustancial que buscan proteger y que, de conformidad con los principios constitucionales y la Teoría General del Proceso (artículos 1, 2, 11, 12, 13 y 14 del Código General del Proceso), 1 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y 228 de la Carta Política, siguen el mandato de la prevalencia del Derecho Sustancial, razón por la cual ha dicho la jurisprudencia constitucional que el poder disciplinario, como único que es y cualquiera que sea, es administración de justicia en sentido material y a sus procedimientos, cualquiera que sea su naturaleza, se les aplican los principios de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (sentencias C-014, SU-901 de 2005 y T-350 de 2011).

Resulta evidente, a la luz del numeral 1.° del artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que los Derechos Humanos Convencionales no solo son oponibles a las autoridades públicas, también lo son a cualquier "*grupo o individuo*" que pretenda destruirlos, menoscabarlos o limitarlos "en mayor medida" que la autorizada por el tratado. El recurso efectivo que debe instrumentar todo Estado cuando se viole un Derecho Humano convencional "*aun cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales*" (artículo 2, numeral 3.° literal a), *ibidem*), lo que presupone necesariamente que también tienen cabida en su protección frente a las acciones de grupos o individuos particulares. También así los artículos 1, 2, 25 numeral 1.° y 29 literal a) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Lo que define los aspectos sustanciales de las instituciones jurídicas no son aquellos de naturaleza instrumental (*legislador, ejecutivo, administrativo o judicial, artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos*), sino el sujeto de derecho –"persona es todo ser humano"– y el derecho respectivo (numerales 1.° y 2.° del artículo 1 *ibidem*). Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a los "*individuos*" quienes encarnan la titularidad de los derechos; ahora, en cuanto a quién sea quien debe garantizarlos, lo es el Estado, bien a través de los instrumentos legislativos, ejecutivos, administrativos o judiciales (artículo 2 numerales 1.° y 2.°). Lo

sustancial es el derecho, el deber o la obligación, independientemente de su reconocimiento instrumental, que es un asunto vinculado con su garantía (artículos 3 –derechos "enunciados", lo que excluye taxatividad– del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 29 literales c y d de la Convención Americana de Derechos Humanos y 94 de la Carta Política).

Lo sustancial está dado por *ii)* y por *v)*, toda vez que allí se encarnan los sujetos de derecho y sus derechos sustanciales, incardinados con sus deberes y obligaciones constitucionales y legales, lo que hace que, por virtud de los artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 29, 30, 31 y 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 228, 229 y 230 de la Carta Política y 1 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el Derecho Disciplinario sea un escenario donde se discierne sobre derechos, deberes y obligaciones, de cuya esencia tenemos que sacar lo que se constituye en los elementos definitorios que elevan al Derecho Disciplinario a la categoría de especie, por fuera de la otra especie del Derecho Sancionador –que se constituye en el género o *ius puniendi*–, que es el Derecho Sancionador Administrativo.

Así y solo así puede afirmarse que nos aproximamos a la Ciencia del Derecho o a la Dogmática, reconocida por la doctrina que la postula como una ciencia autónoma e independiente –preferimos ahora un Derecho Disciplinario Constitucionalizado–, también reconocida sin ambages por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria–, como por la doctrina de la Procuraduría General de la Nación.

Octavo: el Derecho Constitucional y el Derecho Convencional, muy especialmente por los efectos irradiantes de los Derechos Fundamentales y su carácter de fuentes inmediatas del Derecho –artículos 1, 2, 4, 5, 9, 85, 86, 93 y 94 de la Carta Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos–, así como del Control de Convencionalidad –artículo 29 convencional americano–, dejarían corto y minusválido al Derecho Disciplinario regido por virtud de la visión "*doméstica*" que encarna el Derecho Administrativo, en materias como las garantías individuales y la lucha global-internacional contra la corrupción;

Noveno: cómo explicar la facultad sancionadora de las autoridades deportivas en materia disciplinaria en nuestro país si partimos de la teoría de la potestad doméstica, por cierto inutilizable en estos casos desde la perspectiva orgánica y funcional, cuando las mismas están sometidas a fuertes lazos con

autoridades internacionales incluso de naturaleza privada, lo cual no es ya una manifestación excepcional, sino generalizada para todos los deportes[92]; y

Décimo: se avecina la necesidad de un concepto de "*Jurisdicción Convencional*"[93] para poder hacer frente a la problemática que ofrece el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando el servidor público investigado tiene origen en una elección popular, lo que ya de por sí cuestiona la existencia de un Derecho Disciplinario fundado exclusiva y excluyentemente en la potestad doméstica, misma que se encuentra en entredicho por las competencias constitucionales y legales de la Procuraduría General de la Nación para afectar el derecho político a no ser inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por autoridades administrativas. Pronto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Petro *vs*. Colombia –sentencia de julio 8 de 2020, párrafo 120–, así nos lo reveló; allí se estableció el desconocimiento en nuestro orden interno de la prohibición de inhabilitación y destitución de servidores públicos de elección popular, lo que dio pábulo además para efectuar afirmaciones que no se muestran compatibles con la explicación de la potestad doméstica de la Administración, pues la misma da por sentado que existe una pertenencia del Derecho Disciplinario al Derecho Administrativo Sancionador en general, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo acerca muy especialmente al Derecho Penal, al afirmarse que "en el caso Maldonado Ordóñez *vs*. Guatemala, la Corte destacó que '*el derecho disciplinario forma parte del derecho sancionador [...] en la medida en que está compuesto por un conjunto de normas que permiten imponer sanciones a los destinatarios que realicen una conducta definida como falta disciplinaria*', por lo que '*se acerca a las previsiones del derecho penal*' y, en razón de su '*naturaleza sancionatoria*',

---

92 Rojas Urrea, Jorge Andrés & Casas Ortiz, Joaquín Leonardo. "Diálogos entre constitucionalidad, convencionalidad y relaciones especiales de sujeción en el derecho del deporte en Colombia", en *Debates fundamentales sobre Derecho Disciplinario. Ley 1952 de 2019*. Tomo I. Directores: Gómez Pavajeau, Carlos Arturo & Pinzón Navarrete, John Harvey. Ediciones Nueva Jurídica, 2020.

93 Mi propuesta frente a una eventual sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro, hoy una realidad, de manera amplia lo que sería su implementación respetando los estándares convencionales sobre la exigencia del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y sobre la separación de roles procesales de acusación, por un lado, y de juzgamiento y sentencia, por otro –ver párrafos 129, 130 y 137 de la sentencia de julio 8 de 2020–: Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *Dogmática del Derecho Disciplinario*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020, Capítulo I, Parte VI.

las garantías procesales de este '*son aplicables mutatis mutandis al derecho disciplinario*' (párrafo 75)".

La Corte Constitucional ha señalado, por la importancia del Derecho Disciplinario, que la actividad estatal llevada a cabo por autoridades administrativas en tales materias, pues *de iure* así lo son las jurisdiccionales, se constituye en administración de justicia en sentido material, concepto que no se ha extendido a todo el Derecho Sancionador Administrativo, lo cual ya de por sí sugiere una gran diferencia (sentencias C-014 de 2004, SU-901 de 2005 y T-350 de 2011); lo que se encuentra avalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la sentencia Petro *vs*. Colombia, donde se señala igualmente que la actividad estatal en materia disciplinaria, particularmente en Colombia, por cuanto "a través de sus resoluciones determin[a] derechos y obligaciones de las personas[94] [...] ejer[ce] funciones de carácter materialmente jurisdiccional[95]" (párrafo 119).

Acudir a la potestad doméstica como el instrumento que pueda explicar el Derecho Disciplinario en Colombia tiene tanto de ancho como de largo, puesto que allí no se encuentra la explicación para los servidores públicos no sometidos a ella, pero tampoco del sometimiento al Derecho Disciplinario por parte de sujetos particulares vinculados a una función pública y no sujetos a ella.

Si así son las cosas, acusarnos de incurrir en falacias naturalistas no deja de ser un exceso; calificar a nuestros contradictores por incurrir en falacias organicistas, no es un defecto.

Conforme a lo dicho, cada día que pasa estamos más convencidos de un derecho autónomo e independiente –y ahora único– conforme a las precisiones efectuadas o, si se quiere, para no perdernos en discusiones bizantinas, apostamos por un Derecho Disciplinario Constitucionalizado.

---

94 *Cfr*. caso del Tribunal Constitucional *vs*. Perú, supra, párr. 71, y caso Maldonado Ordóñez *vs*. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C n.° 311, párr. 26.

95 *Cfr*. caso Claude Reyes y otros *vs.* Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C n.° 151, párr. 117, y caso Montesinos Mejía *vs.* Ecuador, supra, párr. 176.

1. NATURALEZA CANÓNICA

El Derecho Disciplinario es esencial para la Iglesia Católica y, por ende, en dicho ámbito es aplicable, pero no resulta claro si tal derecho tiene naturaleza pública o privada. Lo único cierto es que es el único derecho que se ha mantenido a lo largo de la historia de nuestra era de manera persistente, permanente y sistemática, influyendo de manera clara y perentoria en la configuración de la historia de occidente y de sus instituciones, que no es otra que la historia del cristianismo occidental. Calcúlese cuál es el peso de la misma si, como se reconoce casi por consenso, el concepto de solidaridad universal fue un invento o creación de Jesucristo –el Jesús Histórico– y hoy perfila y configura los Estados sociales y democráticos de Derecho.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha señalado que los colegios pertenecientes a la religión católica o regentados por su jerarquía caen bajo la órbita de acción del derecho privado y bajo la prohibición del artículo 355 de la Carta Política de 1991 que en su inciso 1.° dice: "Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas del derecho privado". Si esto es así, habría que concluir que la Iglesia Católica y sus instituciones son personas jurídicas de naturaleza privada. Por otro lado, la Iglesia Católica y sus diferentes instituciones pueden firmar tratados públicos con el Estado, lo que entonces apuntaría a decir que su naturaleza y todo cuanto rige a dicha organización tendría la naturaleza de Derecho Público.

La Iglesia no desconoció y menos ocultó su ambición de constituirse en un poder político a lo largo de la historia, ya muy temprano en sus comienzos ello se hizo evidente, lo que los historiadores denominan "*el cristianismo como ideología del Estado*"[96]. El catolicismo también expresó su universalismo en lo que tiene que ver con su vocación de poder, por virtud de su permanente "*compromiso*" con el poder secular que lo conduciría "*hasta el corazón mismo de la política*", relación buscada desde que san Agustín en el año 412, a partir de un pasaje bíblico –"Obliga a entrar hasta que se llene mi casa" (Lucas 14,23)–, interpretó que por virtud del mismo "*un gobierno cristiano tenía la obligación de apoyar a la Iglesia*" en asunto de fe, mediante

---

96 Lomas, Francisco Javier. "El imperio cristiano", en *Historia del Cristianismo*, tomo I: *El mundo antiguo*, Sotomayor, Manuel & Fernández Ubiña, José (coordinadores). Madrid, Trotta y Universidad de Granada, 2005, pp. 481 y ss.

la coerción política hasta llegar la mencionada pretensión a su extremo de ser convertida la Iglesia en Monarquía Pontificia[97].

Lo anterior sirve para recordar la apreciación de Savigny, quien expuso que el Derecho Eclesiástico no se debe subordinar ni al Derecho Público ni al Derecho Privado[98].

Lo cierto es que dicha naturaleza se remonta a tiempos medievales, desde cuando se forjaron los vínculos jurídicos entre los miembros de las órdenes monásticas y los gremios de los oficios con los sujetos encargados de su disciplina. En consecuencia, no solo encontramos aquí una naturaleza del derecho disciplinario de corte clerical, sino que además se vislumbra uno claro como verdadero antecedente de la categoría de la *relación especial de sujeción*, la que fundamenta y explica el Derecho Disciplinario.

La naturaleza canónica del Derecho Disciplinario ha sido magistralmente explicada por Mauricio Rodríguez Tamayo[99], por demás calificada como la mejor opción para explicar el surgimiento de la "*relación especial de sujeción*", así:

> Desde Constantino se concibió la idea de la unicidad entre Iglesia y Estado, donde la Iglesia lo ayudaría "a mantener el orden entre el pueblo, es decir, entre la gente que nunca se volvería inmortal a menos que Dios decidiera salvarla por motivos personales", pero la iglesia lograba el "patrocinio del gobierno", que "puede ayudar a difundir universalmente esas creencias"[100].

> Dicha evolución concluyó, bajo la égida de la experiencia imperial romana, en la identificación entre Iglesia y Estado[101], todo inspirado en lo que los teólogos modernos denominan la "sed de unidad", que conduce, necesariamente, a una "ética unitaria" propia de la cultura judeocristiana[102].

---

97 MacCulloch, Diarmaid. *Historia de la Cristiandad. Los primeros tres mil años,* García Pérez, Ricardo (trad.). Barcelona, Debate, 2011, pp. 184, 339 y 598 a 605.

98 Savigny, Federico Carlos. "Los fundamentos de la ciencia jurídica", en *La ciencia del Derecho*. Buenos Aires, Losada, 1949, p. 45.

99 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. *Naturaleza del Derecho Disciplinario: vicisitudes en la jurisprudencia para su construcción autónoma e independiente en Colombia*. Bogotá, tesis doctoral sin publicar, 2020.

100 Rubenstein, Richard E. *Cuando Jesús llegó a ser Dios*. México, Océano, 1999, pp. 92 y 19.

101 Deschner, Karl. *Historia criminal del cristianismo.* Tomo 1. Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1990, pp. 19, 191 y 200 a 204.

102 Lapide citado por Deschner, ob. cit., p. 64.

> El Rey en el medioevo ostenta su autoridad gracias a Dios, es lo que le otorga legitimidad, de allí que fuera oscilante la mayor o menor cercanía Iglesia y Estado, a veces identidad, durante tal época; lo cual se heredó del "concepto romano de religión como función del Estado", pues sin fe no hay Iglesia y sin Iglesia no hay comunidad, puesto que uno y otra eran formas del mismo cristianismo, ahora bajo la fórmula consolidada del cesaropapismo, como paso de la Púrpura Senatorial a la Púrpura Sacerdotal[103].
>
> El gobernante tenía una función salvífica y la compartía con la Iglesia, por cuanto la salvación de las almas se conseguía por medio de la penitencia colectiva e individual, misma que comprometía la "estabilidad del reino", por tanto, la expiación pública se constituyó en un elemento importante para la "supervivencia política"[104].
>
> La Iglesia le competía rezar para que le fuera bien al gobierno[105]. En la época de identidad entre una y otro, resulta evidente que la misma se constituía en una función oficial –para nosotros aquí, se trataba del equivalente a un servidor público–, empero, cuando se distendía el vínculo, mismo que nunca desapareció en la Edad Media, tenía ocurrencia un fenómeno muy parecido a lo que hoy se aparece como sujetos de derecho disciplinario en tanto "particulares que ejercen funciones públicas".
>
> Sin duda, planteadas, así las cosas, es claro que el antecedente genuino del Derecho Disciplinario, en tanto allí nació la relación especial de sujeción, estuvo en la institución del monacato y en los gremios de oficios, como se ha venido aceptando en este trabajo. El Derecho Administrativo del Estado Liberal, muy difícilmente explicaría, así mismo, una relación especial de sujeción en cabeza de particulares.

La relación especial estaba dada por el vínculo existente entre los monjes y el obedienciario, que era la autoridad disciplinaria monástica encargada de hacer cumplir las reglas[106], y los tribunales eclesiales, únicas instituciones que quedaron en pie después de la caída del Imperio Romano de Occidente

---

103 Jaramillo, M. *De la monarquía imperial a la monarquía cristiana*. Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2004, pp. 112, 113, 130, 143, 182, 183 y 204.

104 McKitterick, R.; Wickham, C.; Devroey, J.; De Jong, M.; Wood, I. & Shepard, J. *La Alta Edad Media*. Barcelona, Crítica, 2002, pp. 151 y 155.

105 McKitterick y otros, ob. cit., p. 160.

106 Para efectos de las autoridades competentes, reglas y demás en las órdenes monásticas, Blaschke, Jorge. *El enigma medieval*. Bogotá, Intermedio y Robin Book, 2004, pp. 32 y 120.

en el año 476[107]; a su vez, la relación general de sujeción estaba dada entre los monjes y el rey a partir de los siglos XI y XII de nuestra era. Esa relación especial de sujeción, en las épocas más álgidas de la integración Iglesia y Estado, que llegaba a confundirse, resultaría el equivalente a un servidor público; cuando se dilataba o flexibilizaba, sería el equivalente a lo que hoy es un particular que ejerce funciones públicas. Las órdenes monásticas –"*se ofrecía, por medio de la oración monástica, satisfacción a Dios por los pecados del gobierno así se mantenía la estabilidad del reino*"[108]– tenían delineada muy claramente la órbita de la relación especial de sujeción que estaba referida a los vínculos con las autoridades monásticas y de los monjes entre sí; la relación general de sujeción con todos los demás, pues "*no suponen una ruptura total con el mundo*", toda vez que "*se mantenía contacto con los de afuera*"[109].

Con respecto a los gremios de oficios[110], con sus autoridades, reglas, destinatarios y sanciones[111], nos encontraríamos ante la posible semejanza con la especie del derecho sancionador que denominamos Derecho Contravencional General, Derecho Administrativo Penal o Derecho Penal Administrativo.

Conceptos verdaderamente revolucionarios, pues demuestran que la relación especial de sujeción no resulta tan antigua como lo propone García Macho –fundada en la relación que surgía en el acto de juramento de lealtad del vasallo hacia el señor feudal, propia de la época de la Alta Edad Media[112]– ni tan joven como lo señala Federico Castillo Blanco –fundada en las competencias específicas del monarca frente al funcionariado (relación especial de sujeción) y las competencias específicas del Parlamento frente a

---

107 MURPHY, CULLEN. *El Tribunal de Dios. La inquisición y el mundo moderno*, ENRIQUE MERCADO (trad.). México, Océano, 2014, p. 43.

108 MCKITTERICK, ROSAMOND. *La Alta Edad Media*. Barcelona, Crítica, 2002, p. 160.

109 MARCOS, MARÍA DEL MAR. "El monacato cristiano", en *Historia del Cristianismo*, tomo I: *El mundo antiguo*, MANUEL SOTOMAYOR & JOSÉ FERNÁNDEZ UBIÑA (coordinadores). Madrid, Trotta y Universidad de Granada, 2005, pp. 670 y 671.

110 *Cfr*. HUBERMAN, LEO. *Los bienes terrenales del hombre*. Bogotá, Panamericana, 2002, pp. 67 a 69 y 90.

111 *Cfr*. PIRENNE, HENRI. *Historia económica y social de la Edad Media*. Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 135 y 136.

112 GARCÍA MACHO, RICARDO. *Las relaciones especiales de sujeción en la Constitución española*. Madrid, Tecnos, 1992.

los ciudadanos (relación general de sujeción)– en la Monarquía Constitucional Alemana[113].

También aquí encontramos puntos de encuentro con Rincón Córdoba, pues estamos totalmente de acuerdo con sus apreciaciones respecto de la existencia de ciertas relaciones jurídicas encontradas en la Edad Media antes que como tales fueran reconocidas por el Derecho Administrativo, tal cual ocurre con instituciones eclesiales y de los gremios de oficio, particularmente del juramento de fidelidad[114]; empero, creo que esto tiene ocurrencia mucho después de la época que propone García Macho para su aparición, cuando se refiere específicamente al juramento de vasallaje, cuando ya se retrotraen las figuras similares a una relación especial de sujeción en una época donde ello no sería posible entenderlo, pues su descripción da cuenta del período llamado de la Alta Edad Media, donde no existió institución en pie diferente a la Iglesia luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, entre los siglos V y X de nuestra era. Ya, a partir de allí, se encuentran instituciones semejantes al Derecho Sancionador Administrativo, como lo reconocemos en nuestros escritos desde muy temprano[115].

El gran aporte de vincular a instituciones medievales la relación especial de sujeción, mucho antes de su aparición formal con la Monarquía Constitucional Alemana, como lo hacen Rincón Córdoba[116] y Rodríguez Tamayo últimamente, ofrece unos horizontes amplios para ir más allá de lo que se desprende de la relación especial de sujeción estrictamente vinculada con el servidor público, pues abre los espacios para entender otras manifestaciones de la institución como sucede con los particulares que ejercen funciones públicas o con el control y supervisión de oficios y profesiones liberales, teniendo como fundamento retrospectivo lo que sucedía ante la institución eclesial y los gremios de oficio.

De todos modos, valga aclarar, Rincón Córdoba no está de acuerdo con que se entienda que la responsabilidad disciplinaria de los particulares que ejercen funciones públicas se encuentra fundada en la existencia de una "*relación especial de sujeción*" que vincula al particular con la Administración

---

113 Castillo Blanco, Federico. *Función Pública y poder disciplinario del Estado*. Madrid, Civitas y Cemci, 1992.

114 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., pp. 48 a 53.

115 *Cfr*. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *Dogmática del Derecho Disciplinario*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 36.

116 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., pp. 48 a 55.

Pública; empero, sí ve viable entenderla en el marco de la llamada "*relación estatutaria*" de origen francés, que explica una vinculación fuerte con la misma, no ya en un plano de la organización, esto es, a partir de un criterio orgánico, pero sí de uno funcional y externo[117]. También nos parece, los aportes de Ospina Garzón permiten una solución en dicha vía[118].

Aclaramos, cuando hablamos del vínculo directo del Derecho Penal con la "*relación general de sujeción*" no quiere decir, ni mucho menos, que sea de él exclusiva y excluyentemente, como lo afirmamos en nuestro primer escrito del año 2001, al mencionar que en el medioevo, al lado de aquel, se perfilan otras ramas del derecho como antecedentes del Derecho Administrativo Sancionador y por supuesto el Derecho Disciplinario, según cita efectuada con anterioridad.

Precisamente, en la cita que nos hace Rincón Córdoba[119], está claro nuestro mensaje y por supuesto no olvidamos nada. Nos referimos al momento de su aparición con la Monarquía Constitucional Alemana –más o menos 1827 o 1828–, pues el sector del Parlamento, enfrentado al de la Monarquía donde regía el reglamento como instrumento jurídico de regulación de conductas, se ocupaba de la limitación de la libertad y de la propiedad que era un asunto exclusivo de la ley. Por supuesto, cuando expreso "*allí comienzan las diferencias*", no estoy hablando de una situación única y estática, sino plural y dinámica que se revela muy claramente cuando abordo su estudio en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción en el Estado Intervencionista, donde las mismas crecen exponencialmente frente a lo que sucedía con las mismas en el Estado Liberal[120–121]. Nadie puede negar que, en gran parte en Derecho Sancionador Administrativo del cual excluimos al Derecho Disciplinario, es un ejemplo multifactorial de expresiones de relaciones generales de sujeción, lo que por supuesto no hace variar el sen-

---

117 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., pp. 120 a 135.

118 *Cfr*. Ospina Garzón. *El fundamento del poder de sanción de la Administración: terapia para el abandono de un complejo*, cit., pp. 33 y ss.

119 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., p. 57.

120 *Cfr*. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo y Molano López, Mario Roberto. *La relación especial de sujeción. Estudios.* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 169 y ss.

121 Muy ilustrativo, Laverde Álvarez, Juan Manuel. "Sanciones administrativas: delimitación conceptual frente a otras actuaciones de la Administración", en *El poder sancionador de la Administración Pública: discusión, expansión y construcción*. XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Alberto Montaña Plata & Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 267 y ss.

tido del Derecho Penal[122], pues resulta obvio que en los delitos contra la Administración Pública se trabaja con la relación especial de sujeción como cofundamentadora de la relación general de sujeción en los llamados delitos especiales, mismos que, al contrario del Derecho Disciplinario, sí dan cabida a la participación criminal de los particulares más allá del *intraneus*, pues los partícipes en delitos como los mencionados –determinadores y cómplices– bien pueden ser *extraneus*, incluso en la figura del interviniente sin calidades como lo establece el inciso final del artículo 30 de la Ley 599 de 2000 por ser la relación general de sujeción su fundamento[123], lo cual hemos tratado con profundidad en múltiples escritos y conferencias internacionales, como tuvo ocurrencia en las Jornadas Internacionales de Derecho Penal del año 2019[124].

Aceptamos que la situación actual del *ius puniendi* en Colombia no se ha podido librar del estigma de la doble sanción por un mismo hecho, sin que resulte calificar de absurda sin más ni más dicha posición, puesto que solo criterios naturalísticos se utilizan en la comparación. Ya una primera campana de aviso, sobre la indeclinable voluntad de abordar el tema, la ofrece la regulación del Principio de Oportunidad en el proceso penal, donde se persigue evitar dichos efectos peyorativos con la causal contemplada en el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. También hemos propuestos mecanismos de superación de la problemática[125]; no obstante, se requiere una ley de integración sistemática del derecho sancionador en general –*ius puniendi*– que regule este tipo de disconformidades.

No otras conclusiones pueden sacarse si, como lo entiende la Corte Constitucional, el Derecho Disciplinario es consustancial a todo tipo de organización, sea esta pública, mixta o privada, como lo pone de presente la auscultación de su naturaleza civil.

---

122 *Cfr*. Rincón Córdoba. *La potestad disciplinaria en el Derecho Administrativo*, cit., p. 58.

123 Rojas López. *Derecho administrativo sancionador*, cit., pp. 130 y 131.

124 Gómez Méndez, Alfonso & Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *Delitos contra la Administración Pública*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pp. 43 y ss. También así en Hernández Esquivel, Alberto; Díaz Soto, José Manuel & Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. "Autoría y participación", en *Lecciones de Derecho Penal. Parte general*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 355 y ss. Muy especialmente en Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. *Estudios de dogmática en el Código Penal de 2000*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020.

125 Así se puede apreciar en cualquiera de las ediciones de nuestra *Dogmática del Derecho Disciplinario*, en el aparte atinente a la regulación del *non bis in idem*.

2. NATURALEZA CIVIL

Del ámbito privado podría derivarse otra explicación del Derecho Disciplinario, por cuanto de las relaciones privadas se deriva la posibilidad de aplicar sanciones pecuniarias y otra suerte de mecanismos propios de las relaciones contractuales. De allí surgieron deberes del oficio y señorío de la administración, en donde esta última podría compeler al trabajador mediante la acción pertinente derivada de la relación jurídica[126].

Ahora bien, creemos que toda organización comporta la necesidad de implementar un régimen de disciplina, por lo que el contacto del Derecho Disciplinario con este tipo de relaciones podría encontrarse en la regulación de las personas jurídicas y muy especialmente en la regulación dada por sus estatutos (artículos 73 y 633 a 652 del Código Civil Colombiano, Ley 57 de 1887)[127].

Pero, además, el Derecho Disciplinario también se da entre las personas naturales, en especial a partir de las relaciones entre los padres y los hijos, en donde los primeros tienen un derecho de corrección sobre los segundos. En efecto, la Corte Constitucional, en importante sentencia, ha recordado lo siguiente[128]:

> Los derechos sobre la persona del hijo que derivan de la patria potestad se relacionan con el derecho de guarda, dirección y *corrección del hijo*. El Código Civil dispone que toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza de sus hijos (art. 253). Derechos que, dado que la patria potestad tiene como fin primordial la protección del hijo en la familia, involucran la obligación de mantenerlo o alimentarlo (Cód. Civil., art. 411) (…); y de educarlo *e instruirlo*; es decir, tienen la dirección de la educación del hijo, *con la facultad de corregirlo* (Cód. Civil., art. 262, modificado por el D. 2820/74, art. 21) la que sólo será legítima en la medida que sirva al logro del bienestar del menor. En efecto, a

---

126 Isaza Serrano, Carlos Mario. *Teoría general del Derecho Disciplinario. Aspectos históricos, sustanciales y procesales*. Bogotá, Temis, 2009, pp. 3 y ss.

127 El artículo 641 dispone: "Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos impongan". El artículo 642, sobre *facultades correccionales*, concreta: "Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de policía correccional que sus estatutos le confieran, y ejercerá este derecho en conformidad a ellos".

128 Corte Constitucional. Sentencia C-1003 de 2007. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

> los padres les está prohibido abandonar al hijo, so pena de perder la patria potestad (Cód. Civil., art. 315 inc. 2.°).
>
> […]
>
> De tal manera, *el derecho de corrección que tienen los padres respecto del hijo menor* no tiene un carácter absoluto, pues encuentra como límite los derechos fundamentales del menor y debe siempre atender el interés superior del niño. Es así como *el derecho de corrección* no puede conllevar la posibilidad de imponerles sanciones que impliquen actos de maltrato, de violencia física o moral, o que lesionen su dignidad humana, o que se puedan confundir con éstos, por ser contarios a la Constitución[129] […] (Cursivas fuera de texto).

Obsérvese cómo las leyes civiles y su jurisprudencia reconocen la necesidad de un derecho correccional o disciplinario, siempre y cuando se entienda que tal prerrogativa no es absoluta, proscribiéndose cualquier sanción que pueda implicar un acto de maltrato, de violencia física o moral, o alguno que lesione su dignidad humana. Si así son las cosas, todo lo demás es el ejercicio de un derecho disciplinario privado, en donde incluso, en la mayoría de las situaciones cotidianas, se aplican elementales principios como los de proporcionalidad y hasta el de culpabilidad, en donde seguramente la intensidad del acto, su conocimiento, voluntad o imprudencia, por ejemplo, incidirán en la manera de ejercer dicho poder correccional.

3. NATURALEZA LABORAL

Históricamente, del Derecho Civil se fue desprendiendo una rama especial denominada Derecho Laboral. En Colombia, ello tuvo lugar en el año de 1950 (decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951, compilados por el Decreto-ley 3743 de 1950). La figura jurídica del patrono y la relación de subordinación del trabajador, la organización del primero por medio de empresas, la terminación del contrato por justa causa, el reglamento de trabajo,

---

129 La Corte Constitucional declaró exequible la expresión "… sancionarlos moderadamente" del artículo 262 del Código Civil, tal como quedó redactado según el artículo 21 del Decreto 2820 de 1974, pero de las sanciones que apliquen los padres y las personas encargadas del cuidado personal de los hijos estará excluida toda forma de violencia física o moral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 42 y 44 de la Constitución Política. Salvaron voto Jorge Arango Mejía, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.

sanciones disciplinarias, procedimiento para imponerlas y reglas sobre el mantenimiento del orden son claras expresiones de disciplina, conforme a las normas laborales vigentes.

Así mismo, como allí también se regulan las relaciones jurídicas surgidas de un contrato de trabajo celebrado entre el Estado y la persona natural, que toman el nombre de "trabajadores oficiales", un sector del derecho laboral comprende una amplia gama de sujetos sometidos a la relación especial de sujeción, por lo que ha primado, al menos formalmente en cuanto al control contencioso administrativo de los actos administrativos disciplinarios que involucren a los mencionados y a los "empleados públicos", una visión inserta en tal naturaleza, pues los tribunales contencioso-administrativos conocen de los asuntos disciplinarios de dicha clase de servidores públicos.

4. NATURALEZA ADMINISTRATIVA

Conforme a este criterio, se afirma que el derecho disciplinario es puro derecho administrativo. Esta teoría es tan amplia que merece ser estudiada desde la doctrina, tanto extranjera como colombiana, y desde la jurisprudencia[130].

4.1 LA DOCTRINA EXTRANJERA

Aquí podemos identificar tres fases del entendimiento del derecho disciplinario con una naturaleza estrictamente administrativa: la fase de la arbitrariedad, la fase moderada y la fase de la legalidad. Veamos cada una ellas.

4.1.1 FASE DE LA ARBITRARIEDAD

Esta es la fase más importante de esta postura tradicional, porque se refiere a la época cuando rigieron con todo su esplendor los llamados principios de conveniencia y oportunidad que gobernaban la figura de la discrecionalidad. Tal época se conoce como la vigencia del derecho administrativo sancionador clásico y ello coincide con la época de un derecho represivo prebeccariano, término utilizado en forma crítica por el mismo Eduardo García de Enterría

130 Para una mejor comprensión y profundidad de estos temas, remitimos al lector a la obra *Dogmática del Derecho Disciplinario* de Gómez Pavajeau, Carlos Arturo, sexta edición, 2017.

en su escrito *El problema jurídico de las sanciones administrativas*, publicado en 1976.

La fase de la arbitrariedad, según Rivero, tuvo fundamento en la influencia del origen napoleónico del derecho administrativo, en donde la administración era dueña de sus actos, los cuales no se encontraban insertados en el marco de la legalidad. Podría decirse que era una situación absolutamente antagónica a lo que hoy se entiende por la aplicación y respeto del principio de legalidad. En esa época no regía el principio de legalidad de las descripciones típicas y de las sanciones, pues el castigo solamente se imponía cuando la necesidad lo exigía y solo para los fines eminentemente administrativos.

De la misma manera, y como apenas es obvio, en dicha época nada se decía acerca de la responsabilidad subjetiva, por lo que es claro que tampoco operaba el principio de culpabilidad. En síntesis, operaba una discrecionalidad, con todo su esplendor y con todas sus consecuencias, esto es, la no vigencia del principio de legalidad, ni mucho menos su consecuente de tipicidad, ni remotamente el análisis subjetivo de la conducta.

4.1.2 FASE MODERADA

Se trata de una fase en donde lenta y progresivamente se empezaron a reconocer mayores garantías. Ello puede observarse en autores como Gabino Fraga, quien afirmaba que la falta disciplinaria se origina en el incumplimiento de los deberes que impone la función pública, lo cual suponía una relación de dependencia especial, agregando que la pena disciplinaria se aplica por la autoridad administrativa, quien tiene discreción para calificar la falta, el procedimiento y la sanción[131].

En esta fase se empieza a describir lo que es falta disciplinaria y a afirmarse que es necesario que las sanciones se encuentren vinculadas a la ley, dejando un estricto margen para la discrecionalidad administrativa. En esta etapa, el principio legalidad no es un principio para algunos autores, pero por lo menos empieza a ser exigible en la medida de lo posible. De la misma manera, se empieza hablar sobre la necesidad de una razonable discrecionalidad, tanto como la gradación de la sanción.

---

131 FRAGA, GABINO. *Derecho Administrativo*. México, Porrúa, 1973, pp. 170 y 171.

En fin, son muchos los cambios en cuanto a la concepción de la fase de la arbitrariedad a la fase intermedia, las cuales podemos resumirlas de la siguiente manera:

1. La ampliación cualitativa y cuantitativa de los eventos controlables por la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con la evolución jurisprudencial.

2. La introducción de las modernas técnicas de administración, especialmente las de personal.

3. La vinculación de los reglamentos no solo de los administrados sino también de la administración.

Esta fase en síntesis se caracteriza por buscar el reconocimiento del principio de legalidad y su consecuente de tipicidad, o, al menos, implantar la legalidad de las sanciones. Así mismo, y aunque algunos autores reclamaban la imputación subjetiva a título de intención y culpa, lo cierto es que en esta fase no alcanzó a implementarse a plenitud el principio de culpabilidad.

4.1.3 FASE DE LA LEGALIDAD

La evolución de esta concepción se completa con la exigencia del principio de legalidad y la prohibición de la analogía en materia de construcciones típicas. También entra a operar el principio de legalidad de la sanción.

Por su parte, en la prefiguración del régimen disciplinario también tendrá cabida el reglamento como forma de especificar los mandatos de la ley, siempre que el núcleo del ilícito quede establecido en esta; por tanto, "los reglamentos del régimen disciplinario tipifican una serie de faltas o infracciones administrativas relativas a los deberes y obligaciones del funcionario, de acuerdo con la legalidad vigente"[132].

Esta fase se caracteriza por la admisión fuerte del principio de legalidad, frente a lo cual podemos advertir lo siguiente:

1. El núcleo de lo ilícito se encuentra en la infracción del deber funcional.

2. Se empieza a reconocer el principio de culpabilidad. En una primera etapa, como una presunción en donde se admitía prueba en contrario. En un segundo momento, en donde se introduce el requisito de la voluntariedad de la acción, en la cual, si bien no comporta la presencia de dolo y culpa,

---

132 LAFUENTE BENACHES, MERCEDES. *El régimen disciplinario de los funcionarios públicos de la administración del Estado*. Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, p. 16.

por lo menos sí se exige el vínculo psíquico entre el sujeto, el querer y el resultado. Obviamente aquí la concepción de la culpabilidad únicamente se circunscribió al aspecto psicológico, quedando pendiente el componente eminentemente normativo.

3. Se reconocen algunas situaciones de exención de la responsabilidad, tales como el caso fortuito, la fuerza mayor y la *vis absoluta*.

4. Se abandona toda posibilidad de responsabilidad objetiva; por ende, habrá una mayor subjetivización para comprender la infracción y la culpabilidad.

5. Aunque el dolo en esta fase no se considera un componente de la responsabilidad, sí al menos es tenido en cuenta como criterio de graduación de la sanción. En esta fase la base de la responsabilidad es la culpa, pues casi todas las infracciones administrativas terminan tipificando la imprudencia. En esta fase hay un verdadero sistema imputación *crimina culpae*.

4.2 LA DOCTRINA COLOMBIANA

La doctrina colombiana ha enseñado que la potestad disciplinaria aplicable a los servidores públicos deriva modernamente de las nociones de jerarquía, competencia y disciplina propias de la ciencia de la administración. De la noción de jerarquía emanan el poder de mando o jerárquico, la subordinación y el deber de obediencia, y como tal entonces el poder disciplinario. Pero también la administración exige disciplina a los particulares "por razones de disciplina y eficiencia en el servicio público y en el ejercicio de la función administrativa", la cual toma el nombre de potestad correccional, cuyo fundamento se encuentra en el llamado poder de policía propio de las funciones presidenciales[133].

Rojas Arbeláez señala los requisitos que entiende necesarios para decretar la responsabilidad disciplinaria, coincidentes con los que surgen del principio de legalidad; empero, se mueve en el ámbito de la responsabilidad objetiva[134].

Enríquez cumple con el principio de legalidad, pero niega la culpabilidad, pues para que exista falta disciplinaria requiere el desarrollo de una conducta por un servidor público, durante el ejercicio del cargo, que viole el

---

133 Rodríguez Rodríguez, Gustavo Humberto. *Derecho administrativo general*. Segunda edición. Bogotá, Ciencia y Derecho, 1995, pp. 38 a 41.

134 Rojas Arbeláez, Gabriel. *El espíritu del derecho administrativo*. Bogotá, Temis, 1985, p. 87.